

歷久彌新或不合時宜？^{*} ——民法不動產物權時效取得制度之實踐與革新

張永健^{**}

摘 要

時效取得制度歷史悠久，但在當代臺灣正當性搖搖欲墜。近年之時效取得案件，幾無占有人成功取得不動產物權。法院錯誤解釋構成要件，未登記土地幾乎遞減到零，地狹人稠，地政資訊之電子化，都是原因。無權占有人難以符合現行法下的時效取得要件，表示立法者應該修法放寬時效取得要件，還是時效取得應該功成身退？檢視6年不動產時效取得案件後，本文以法律經濟分析方法，主張時效取得制度已不適合當代臺灣。主張不動產物權時效取得之占有人應被推定為惡意，且惡意占有人不得時效取得物權；即使能證明自己為善意無過失占有者，也只能在符合其他嚴格條件時，時效取得已登記土地之定限物權，或時效取得未登記定著物之所有權。

* 投稿日：2014年12月16日；接受刊登日：2015年6月29日。〔責任校對：黃莉婷〕。

筆者感謝王玠涵、陳憶馨、曾鈺琄、李孟穎、林明忠、陳榕、林琮達之研究協助。本文初稿發表於2014年3月18日中研院法律所個人年度學術研討會、2014年5月15日北京清華大學博士生講座、2014年6月16日財產法暨經濟法研究協會主辦之2014兩岸四地不動產研討會，感謝主持人溫豐文教授、申衛星教授，評論人吳瑾瑜教授、王進祥教授，與會者劉孔中教授、李建良教授、簡資修教授、廖福特教授、黃舒芃教授、邱文聰教授、許家馨教授、吳宗謀教授、陳磊教授、喬仕彤教授、吳萬順董事長之寶貴意見。本刊兩位匿名審查人、編輯委員會亦提供非常重要之修正建議。本文為筆者執行科技部計畫101-2410-H-001-020-MY3「占有：比較、經濟、實證分析」之部分研究成果；感謝科技部的研究補助。

** 中央研究院法律所副研究員、法實證研究資料中心執行長。
穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/92210151.pdf>。



關鍵詞：惡意、善意無過失、可得而知之善意、已登記、未登記、不動產、土地、定著物、占有事實之推定。

目 次

壹、導論	參、建構新時效取得制度
貳、時效取得判決之實證鳥瞰與實務批判	一、既有三種理論回顧與檢討
一、不動產時效取得案件之態樣	(一) 權利睡著理論
二、「取得地上權之意思」之解釋	(二) 損失厭惡理論
(一) 學說、實務見解	(三) 有效率侵害理論
(二) 自主占有、他主占有、時效取得問題中之占有	二、時效取得制度改革芻議
(三) 取得地上權意思之認定	(一) 有登記不動產與惡意占有
(四) 舉證責任歸屬	(二) 有登記不動產與善意占有
	(三) 未登記不動產與惡意占有
	(四) 未登記不動產與善意占有
	肆、結論

壹、導論

從羅馬法創設時效取得制度¹以來，除了中國以外²的各國現代民法，幾乎都明文繼受時效取得制度³。此制度之淵遠流長與廣泛接受，可見一斑。司法院大法官很少觸及民事財產法問題，但卻四度正面處理⁴不動產時效取得制度（司法院釋字第291號、第350號、第408號、第451號解釋）⁵，而且三度宣告相關法令違憲。由大法官的積極態度，直覺的推測是，時效取得制度在發明後2000年的當下，仍然蓬勃興盛、案例眾多。然而，深入耙梳近來相關普通

- 1 關於羅馬法上的時效取得制度，參見溫俊富，時效制度的根據——十七世紀到民法典制度之際法國時效觀的演化，收於：司法院謝前副院長在全七秩祝壽論文集編輯委員會編，物權與民事法新思維——司法院謝前副院長在全七秩祝壽論文集，頁229-233（2014年）。
- 2 關於中國物權法未納入時效取得之分析檢討，參見張永健，芝大法律經濟學與中國物權法——方法論的展現與辨正，法律與社會科學，12卷，頁8-12（2013年）。
- 3 關於各國立法例，參見曾國修，所有權取得時效之存在理由及其要件構成——民法物權編部分條文修正草案之檢討與建議，收於：黃宗樂教授祝壽論文集編輯委員會編，黃宗樂教授六秩祝賀——財產法學篇（一），頁179-183（2002年）。英美、歐陸國家時效取得制度之比較經濟分析，see UGO MATTEI, BASIC PRINCIPLES OF PROPERTY LAW: A COMPARATIVE LEGAL AND ECONOMIC INTRODUCTION 114-17 (2000); EIAN MACKAAY, LAW AND ECONOMICS FOR CIVIL LAW SYSTEMS 278-79 (2013)。比較法上，有些國家之立法策略是讓原所有人之所有物返還請求權罹於時效；有些國家如臺灣是讓占有人因時效經過而取得物權。See J.E. Jansen, *Thieves and Squatters: Acquisitive and Extinctive Prescription in European Property Law*, 1 EUR. PROP. L.J. 153, 153-58 (2012)。民法將時效取得規定緊接在所有物返還請求權（民法第767條）後，顯然是意識到兩規定的緊張與緊密關係。
關於臺灣民法之不動產時效取得規定，主要乃繼受瑞士而非德國立法例，參見陳自強，登記生效與登記對抗之間，月旦法學雜誌，227期，頁48（2014年）。
- 4 司法院釋字第107號解釋也側面探討了時效取得制度。此外，司法院釋字第400號解釋所言之「公用地役權」，其實某程度也是時效取得問題，只是取得主體是不特定人，不是現行法規範意義下的時效取得。
- 5 關於這幾號司法院大法官解釋之批評，參見蘇永欽，財產權的保障與大法官解釋，憲政時代，42卷3期，頁45-48（1998年）；林明鏘，國土計畫法學研究，頁83-88（2006年）。針對司法院釋字第408號解釋之評釋，參見陳立夫，土地法研究，頁188-192（2007年）；陳立夫，土地法研究（二），頁66-67（2011年）（以下稱：陳立夫，土地法研究（二））。

法院民事判決後可知，相關爭訟並不算多（統計數據參見本文第貳部分），成功時效取得之案例，更是稀少⁶。

何以昔之熇熇而今之涼涼⁷？部分原因則是法院對相關條文之解釋，使得時效取得更加困難⁸；部分原因是民法的構成要件在大環境變遷後，變得對時效取得人十分嚴苛。例如，民法第769條規定，時效取得所有權之標的，限於未登記之不動產。本條在1930年制訂時，中國想必遍地是未登記不動產。然而，在2012年底，臺灣本島、澎湖、金門、馬祖之土地總面積為36,192.82平方公里，已登記之土地面積為3,493,7.12平方公里⁹，亦即未登記土地之比率為3.47%。如圖1所示，自有資料的2005年以來，臺灣已登記土地之比例快速上升¹⁰，未登記土地之面積與比例大幅減少¹¹。2009年後成長趨於和緩，或許是因為剩下之未登記土地，多屬土地法第41條¹²所規定「免予編號登記」之土地¹³；而此種土地依實務見解¹⁴，並

6 法院判決數目並不當然反映了時效取得制度之使用頻率；更多討論參見第貳部分。

7 典出明朝劉基《郁離子》〈靈邱丈人〉，請參見百家諸子 中國哲學書電子化計劃，<http://ctext.org/yulizi/lingqiuzhangren/zh>（最後瀏覽日：2016年2月24日）。

8 例如認為未登記之不動產不包括免予編號登記之土地。參見謝在全，民法物權論（上），6版，頁157（2014年）。

9 土地總面積統計數據來自：中華民國統計資訊網，<http://ebas1.ebas.gov.tw/pxweb/Dialog/Saveshow.asp>（最後瀏覽日，2014年2月5日）；已登記土地面積之統計數據來自：內政部統計年報，<http://sowf.moi.gov.tw/stat/year/list.htm>（最後瀏覽日：2014年2月5日）。

10 請注意，先前有文獻以2006年底（當時臺灣仍有16%土地未登記）之數據探討時效取得問題，其背景又與今日不同。參見許松、張梅英、陳良駿，未登記土地以時效取得所有權之探討，土地問題研究季刊，7卷3期，頁20（2008年）。

11 已登記土地比率大幅上升，似乎並未廣為周知。是故，法務部2003年成立的物權編修法小組，以及在2009年審議時效取得相關條文之立法者，思考相關問題時或許都還隱然假設臺灣有許多未登記土地。

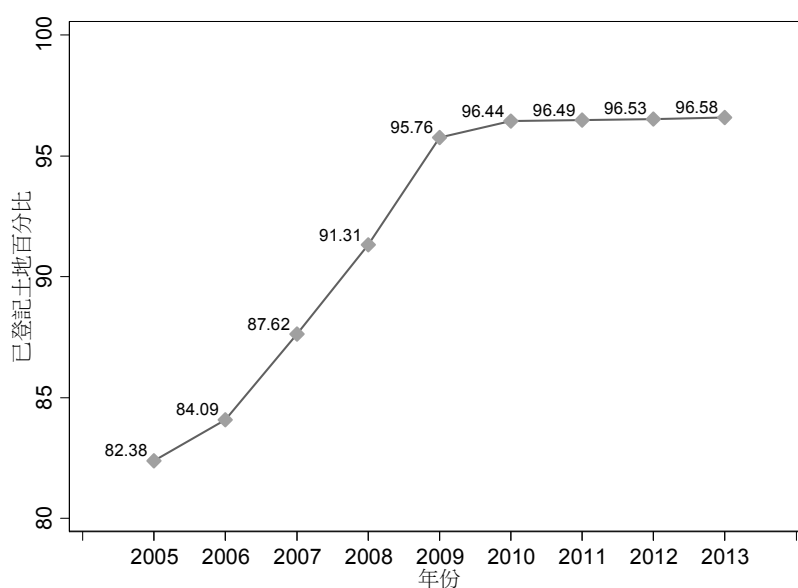
12 土地法第41條：「第二條第三類及第四類土地，應免予編號登記。但因地籍管理必須編號登記者，不在此限。」

13 對2006年時之未登記土地，學者作此種推測。參見許松、張梅英、陳良駿（註10），頁20。

14 參見例如：最高法院65年台上字第2558號民事判例：「系爭土地既係水利用地（排水溝間堤防用地），依法免於為所有權之編號登記，上訴人自無從因時效之

非不動產所有權時效取得之客體¹⁵。因此，臺灣真正可能成為所有權時效取得客體之土地，少於3.5%。甚至有學者認為，在臺灣要時效取得不動產所有權，幾乎不可能¹⁶。

圖1 臺灣已登記土地佔全部土地之百分比，2005–2013年



數據來源：內政部統計年報。百分比為本文自行計算；各年的臺灣總面積均包括澎湖、金門、馬祖，並假設與2012年底同為36,192.82平方公里。

完成而取得及請求登記其地上權。」實務見解之整理，參見楊松齡，時效取得制度之「未經登記不動產」之探討，收於：黃宗樂教授祝壽論文集編輯委員會編，黃宗樂教授六秩祝賀——財產法學篇（一），頁134（2002年）。

15 學者有主張，「未登記之不動產」應該解釋為「未登記真正權利人名義」。參見楊松齡（註14），頁178；江宛瑛，論未登錄保安林地及河川地之時效取得地上權或所有權，現代地政，275期，頁27（2004年）。

16 參見楊松齡（註14），頁132；謝哲勝，財產法專題研究，頁169（1995年）；謝哲勝，時效取得地上權，收於：蘇永欽編，民法物權實例問題分析，頁58（2001年）（以下簡稱：謝哲勝，時效取得）。

然而，有認為臺灣應仍有未登記且為時效取得客體之不動產。參見許松、張梅英、陳良駿（註10），頁21-24；謝依婷，我國不動產時效取得之研究，國立中正大學法律學研究所碩士論文，頁53-54（2012年）。

為更細緻探究現行時效取得條文在法院運作的問題，第貳部分抽樣分析2006年到2011年地方法院之不動產時效取得判決¹⁷。由該部分之歸納分析可知，運用時效取得條文之判決雖不少，但「長期占有人¹⁸」透過訴訟而成功時效取得者，非常稀少。假設大多數時效取得之爭議都進入法院¹⁹，並獲得第一審判決²⁰，則第貳部分顯示，時效取得制度在現代臺灣已經沒有太大的實用性，幾近名存實

17 為了研究法律見解，學者通常分析最高法院判決、判例，王澤鑑教授之八本「民法學說與判例研究」即為適例。近來，學者為了觀察相關爭議的事實態樣，並避免「選擇偏誤」(selection bias)，開始有系統地研究大量地方法院之訴訟。參見黃國昌，律師代理對民事訴訟結果之影響——理論分析與實證研究間之激盪，中研院法學期刊，1期，頁45-104（2007年）（以下簡稱：黃國昌，律師代理）；黃國昌，我國勞動訴訟之實證研究——以第一審訴訟之審理與終結情形為中心（上），政大法學評論，106期，頁203-247（2008年）；黃國昌，我國勞動訴訟之實證研究——以第一審訴訟之審理與終結情形為中心（下），政大法學評論，107期，頁165-228（2009年）；Kuo-Chang Huang, *Does Discovery Promote Settlement? An Empirical Answer*, 6 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 241 (2009); Kuo-Chang Huang et al., *Does the Type of Criminal Defense Counsel Affect Case Outcomes?: A Natural Experiment in Taiwan*, 30(2) INT'L REV. L. & ECON. 113 (2010)；張永健，共有物分割判決之實證研究，收於：張永健編，2011司法制度實證研究，頁221-264（2013年）；張永健，袋地通行權判決之實證研究，月旦法學雜誌，216期，頁211-227（2013年）；張永健，越界建築訴訟之實證研究，中研院法學期刊，14期，頁327-373（2014年）（以下簡稱：張永健，越界建築）。

18 本文所說之長期占有人，並不排除依民法第770條以短期取得時效者。

19 這並非不合理之假設，依據土地法第54條、土地登記規則第108條第2項、土地登記規則第118條，有意時效取得者必須檢具相關文件向地政事務所提出申請（以時效取得為原因申請地上權登記，須先申請土地複丈，複丈後地政事務所才會受理申請），受理後地政事務所審查無誤後即公告，並通知土地所有人。法定期間內無人異議，才會直接准其登記；如有人異議，由地政機關予以調處，不服調處，須於接到調處通知後十五日內提起訴訟。可以推想，大多數時效取得爭議，不會直接登記或調處終結，而會進入法院。參見詹森林，所有物返還請求權——系列問題（四）無權占有人之三，月旦法學教室，5期，頁41（2004年）。

20 不過，必須進入法院，不代表會獲得判決，當事人仍然可以在判決前和解。占有人即令可能勝訴，仍可能接受所有人的和解金額，自願放棄時效取得物權。若此種結果不少，則受益於時效取得制度之占有人，會比本文實證觀察所顯示者為多。這是需要法實證研究的問題，也不是不可能推估，但必須主管機關內政部地政司提供大量數據資料才能作。關於地方法院案件和解率之實證研究，參見黃國昌，律師代理（註17），頁45-104。

亡²¹。此外，如前論及，長期占有人難以透過時效制度取得所有權，部分導因於法院不盡合理的法條解釋方式（例如對於「以行使地上權意思」之解釋），第貳部分將提出商榷意見。

第貳部分顯示，現行不動產時效取得制度，被立法內容、（時有錯誤之）司法解釋、其他法制與大環境遷移而架空。第參部分則探究不動產時效取得制度何去何從。本文之所以要建構一套新的「不動產²²」時效取得制度，除了現制淪為「雞肋」——留之無味、棄之可惜——少有實際應用之機會外，也是因為從理論層面，現行不動產時效取得制度，在當代臺灣，不符合「經濟效率」²³。物權制度之經濟效率無法抽象判斷，然後放諸四海。經濟分析是條件式論述——給定某些條件後判斷。本文第參部分參酌在美國法情境中發展出之不動產時效取得經濟分析理論，以此理論基礎，考量臺灣地狹人稠、地政資訊透明公開、人民教育水平不低、對不動產法制有基本理解等等條件後，倡議新制度。因此，本文並非主張將美國之時效取得制度搬到臺灣，而是化用粲然大備於美國的經濟分析理論。本文並非比較法論文，合先敘明。

運用法律經濟分析方法²⁴，本文建構最符合經濟效率之不動產

21 法律史學者吳宗謀教授向筆者指出，歷史上時效取得制度要扮演重要角色，是在大環境劇烈變革時，如歐洲十字軍東征時。東西德統一時，亦有東德居民欲時效取得無人照管之前共黨黨產。對照臺灣經驗似乎也是如此，金門、馬祖實施戰地政務多年，回歸一般法制的數年間，產生大量時效取得爭議（參見本文第貳部分）。或許，留下時效取得制度，純粹是為了「以備大環境日後變遷時之不時之需」。但有趣的是，正處在制度轉型過程中的中國，卻選擇不在物權法中承認時效取得制度。

22 動產時效取得問題點不完全相同，不在本文論述範圍內。

23 關於效率之定義，以及在分析臺灣物權法問題時如何運用經濟效率作為分析指引，參見張永健，物權法之經濟分析導論（二）——效率，月旦法學雜誌，231期，頁196-201（2014年）。

24 關於時效取得之經濟分析，參見例如葉秦寧，不動產時效取得相關問題之法律經濟分析，國立政治大學地政研究所碩士論文，頁1（2005年）。分析美國時效取得制度之經濟分析文獻甚多，以下會在適當處引用之。

時效取得制度。簡言之，切合臺灣現今制度環境之不動產時效取得制度，應以如下方式重新建構：欲主張時效取得者應一律被推定為惡意占有，而唯有善意無過失之占有人，才可能在強調事後觀點或個案救濟之前提下，非常有限度地承認其時效取得物權。而且，時效取得制度並非免費。有意時效取得有登記土地上之定限物權者，應支付原所有人整個占有期間以市價計算之相當於租金之不當得利。時效取得定限物權後亦必須支付租金。沒有長期投資之占有人（例如只為了方便而習慣自某處通行者），不得時效取得定限物權。未登記之不動產中，僅有未辦理保存登記之定著物，有必要建置時效取得制度。占有人要以按時繳納房屋稅及其他證據證明其為善意無過失。若占有人或其前手未曾針對系爭定著物給付價金給原權利人或其前手，則在申請時效取得登記時，必須一併給付公平市價予能證明為權利人者。

貳、時效取得判決之實證鳥瞰與實務批判

要確知時效取得究竟能否成功，最直接且清楚的方式，就是探究每一年每一縣市有多少時效取得所有權與時效取得他項權利之登記。各縣市地政事務所辦理登記時，有將這兩種時效取得列為獨立之「標準登記原因」，各筆土地之異動資料也都有保存。然而，主管地政的內政部，每年出版的統計年報並未匯報時效取得之統計資料，也沒有公開數據庫供外界查閱。筆者多次函詢內政部地政司索取相關數據，均未果²⁵。退而求其次之作法，是觀察判決。如果土地占有人申請時效取得登記，而登記名義人沒有異議，不會有訴訟。是故，判決中之時效取得成功率必然低估了實踐上之時效取得成功率。但就本文目的而言，此種低估並非硬傷。首先，時效取得

25 相同缺乏統計數據之喟嘆，參見王澤鑑，民法物權，2版，頁169（2010年）。

已經名存實亡，並非本文第參部分對時效取得制度之反省與重構之必要條件。再者，回顧時效取得相關之民事判決，也有在制度未轉變之前，矯正法院對時效取得制度錯誤見解之功能。不過，本文確實假設大多數登記名義人會異議，所以時效取得爭議會進入法院，從而法院判決中時效取得成功率，能供吾人判斷時效取得是否仍被實際使用。

須注意者，部分申請登記時效取得物權未果者，會提起行政訴訟。因本文重點在民法上之時效取得問題，相關行政法上之爭議，本文不會進一步論述其內容。本文關心者為行政法院是否經常准許時效取得登記之申請。本文利用法源法律網之裁判資料庫，檢索臺灣最高行政法院以及臺北、臺中、高雄三處高等行政法院，分別自民國87年起以及89年7月起至檢索日（103年11月17日），以「時效取得」作為檢索關鍵字，搜尋時效取得不動產所有權、用益物權之判決。搜尋後扣除「土地複丈」、「申請使用執照」、「國軍老舊眷村改建條例」、「建築執照」、「徵收補償」、「公用地役關係」等未實質判斷民法時效取得構成要件之案件，共得497筆相關判決。其中僅有18筆案件（4%）中，申請時效取得登記者，在向登記機關申請時效取得未果後，尋求行政法院救濟，並因而得到行政機關重新做成處分的機會。但這些案件中，行政法院雖命行政機關更正判斷上之瑕疵，並重新做成處分，但這不代表法院認定申請人主張時效取得有理由，也不代表登記機關最終會做出准予時效登記之決定。換言之，藉由行政訴訟而成功時效取得者，亦屬鳳毛麟角²⁶。

26 這18筆判決為：高雄高等行政法院91年度訴字第417號判決；臺中高等行政法院98年度訴字第203號判決、97年度訴字第180號判決、92年度訴字第898號判決、92年度訴字第654號判決；臺北高等行政法院102年度訴字第1034號判決、102年度訴更二字第90號判決、102年度訴字第1077號判決、101年度訴字第162號判決、94年度訴字第750號判決、93年度訴字第3523號判決、93年度訴字第3810號判決；最高行政法院94年度訴字第1705號判決、91年度訴字第1828號判決、90年度訴字第2367號判決、90年度訴字第760號判決、88年度訴字第3506號判決、87年度訴字第1811號判決。

本部分以下探討不動產時效取得之第一審適用普通訴訟程序之民事判決。在法源法律網搜尋2006年1月1日～2011年12月31日間，地方法院之不動產時效取得判決，共得700筆²⁷，其在各地方法院之分布，參見表1。值得注意者，以往學者研究臺灣地方法院之物權問題時，發現金門與馬祖之相關判決非常稀少。但在時效取得問題，金門與馬祖之判決數目甚多，與其土地面積或人口不成比例²⁸。

因研究資源有限，本文分層隨機抽樣1/4判決作為研究客體²⁹。最終，納入本文資料庫之不動產所有權時效取得案件計有55筆，不動產定限物權時效取得案件計有107筆；共162筆。

第一節鳥瞰不動產所有權與定限物權時效取得案件之原因事實與判決結果。第二節集中火力探討最需辨正觀念時效取得構成要件——以行使所有權／地上權之意思而占有他人之物。

由於行政法問題並非本文重心，本文就不一一過濾數量龐大的訴願案件。

27 詳言之，本文分兩部分搜尋判決。第1部分的關鍵字是「民法第769條+民法第770條+民法第七六九條+民法第七百六十九條+民法第七七〇條+民法第七百七十條」，共得492筆判決。這是為了搜尋不動產所有權時效取得之案件；但因為不動產定限物權時效取得之案件也有時會引用這兩條，所以本部分的搜尋結果混合了定限物權時效取得之案件。第2部分的關鍵字是「民法第772條+民法第七七二條+民法第七百七十二條-民法第769條-民法第770條-民法第七六九條-民法第七百六十九條-民法第七七〇條-民法第七百七十條」。本次搜尋是為了捕捉漏網之魚——有些不動產定限物權時效取得之判決，只會引用民法第772條，而沒有提及民法第769條與第770條。但為免和第1部分之搜尋重複，關鍵字設定時將有提及民法第769條與第770條之判決剔除。

28 外島的案件多，原因是金門與馬祖屬於戰地多年，許多政務推展與本島不同。如福建連江地方法院94年度訴字第9號民事判決所述：「連江縣地政事務所係成立於八十二年間，該所成立前，係由縣府地政股承辦地政業務，又連江縣係自六十五年開始依土地法及土地登記規則辦理全縣土地總登記，而該次總登記程序，於全縣約十分之一土地辦理總登記完畢後，即因故停滯，待連江縣地政事務所成立後，縣府地政股即將保有之六十五年地籍圖與相關之登記簿冊移交該所保管……」。

29 第1部分與第2部分之判決分開抽樣。各自以「法院」為單位分層抽樣。

表1 時效取得判決數目

法院別	§769 & §770	§772	法院別	§769 & §770	§772
臺北	66	50	雲林	8	6
士林	26	16	嘉義	18	5
板橋	43	27	臺南	20	4
宜蘭	13	4	高雄	45	9
基隆	16	9	花蓮	10	13
桃園	37	32	臺東	8	8
新竹	23	10	屏東	9	3
苗栗	6	4	澎湖	3	1
臺中	31	14	金門	36	0
彰化	18	14	連江	44	0
南投	12	5			
			總計	466	234

原始數據來源：法源法律網。本文製表。

一、不動產時效取得案件之態樣

不動產所有權時效取得案件與不動產定限物權時效取得案件之數目比為1:2。後者幾乎都是時效取得地上權的案件。整體而言，只有6%（10筆³⁰）的案件中，長期占有者成功時效取得（參見表2、下述討論）³¹。95%的案件涉及土地之時效取得，5%關於地上

30 如後所論，法院在部分案件中認定之時效取得，頗有疑義。但以下數表的統計數字，仍以法院判決認定者為準。

31 未成功時效取得之案件，例如：福建金門地方法院99年度城簡字第40號民事判決（防空洞乃公物，無法時效取得）；臺灣士林地方法院98年度訴字第410號民事判決（事實上處分權無法成為時效取得之客體）；臺灣雲林地方法院98年度訴字第416號民事判決（占有人沒有申請所有權登記）；臺灣臺北地方法院100年度訴字第134號民事判決（時效取得之客體為原住民保留地，然其申請未依照特別法令——山坡地保育利用條例第37條、原住民保留地開發管理辦法第9條、原住民保留地各種用地申請案授權事項及申請作業須知第3條）。

物³²（參見表3）。涉及時效取得定限物權之案件中，88%案件之標的物是有登記之土地，只有12%的土地是未登記之土地³³（參見表4）；國有與私有土地均有（參見表5）³⁴。占有人在占有之始是否善意、有無過失很少提及，一方面，不能時效取得者，會在其他要件栽跟頭；另一方面，能時效取得者，通常占有時間久遠，超過20年，無論占有之始為善意或惡意均能符合此部分要件，故法院未特別檢驗之。

未能時效取得之理由，態樣眾多。法院通常不會窮盡分析所有構成要件，而是一旦證立某關鍵要件不合，即判定不能時效取得。故以下之理由分析，並不表示長期占有人萬事俱備、只欠東風，而往往只是顯示法院慣常先檢驗的構成要件為何。在時效取得所有權案件，42%之案件涉及有登記土地，非常客觀明確，不可能時效取得。在定限物權時效取得案件，85%之案件是因為沒有取得地上權之意思或沒有在所有人請求返還前向地政事務所申請登記³⁵（參見表6）。未申請登記與沒有取得物權意思，在時效取得所有權案件也不少（參見表6）。

初看本文數據，會令人驚訝：成功取得所有權之案件比率（與數目），竟高於成功取得定限物權之案件比率（數目）³⁶。但仔細閱讀法院認為成功時效取得的十筆案件，會發現成功時效取得所有權之案件，往往有其特殊或錯誤之處。舉例而言：一案中，原告（請求確認登記為土地所有人之權利存在）是主張其父親與祖父在清朝末年開始占有系爭土地數十年；但從1950年代開始即為軍方占

32 兩者之時效取得比率，沒有統計上顯著差異。

33 兩者之時效取得比率，沒有統計上顯著差異。

34 此外，有學者觀察到，實務上案例多屬「國有未登記土地」。參見王澤鑑（註25），頁177。

35 即便各項要件均符合，只要長期占有人沒有即時申請登記，依據向來實務見解（如最高法院92年度台上字1867號民事判決），無法時效取得。

36 前者比率（10.9%）統計上顯著地高於後者比率（3.8%）， $p=0.0367$ 。

有。本件原告能勝訴，是依據已經廢止多年的「金門馬祖東沙南沙安全及輔導條例」，否則依據民法規定，原告早已喪失占有，無從主張登記為土地所有人³⁷。

一案中，爭點不在是否時效取得；作為判決基礎之時效取得已於1993年完成，長期占有人早已登記為所有人³⁸。

本文抽樣到兩個案件，一案為第一審判決³⁹，另一案為其再審之訴⁴⁰。該案之占有人於1985年到2007年間占有國有未登記土地。原告國有財產局在第一審時即提出一個很有意思的論點：占有人一方面宣稱系爭土地是祖產，另一方面卻請求地政機關作時效取得所有權之登記，顯有矛盾，因為後者必須以占有「他人」不動產為前提。法院未接受此論點，因為占有人並未證明系爭土地是祖產，只是空口說白話。國有財產局依此論據又提出再審之訴。占有人這次則回應：占有之祖先因為長期占有，早已將系爭土地視為己有，但因為馬祖長期未設有登記機關，占有之祖先因而無法登記為所有人。待占有人申請登記時，依據民法該土地並無所有人，故屬「他人土地」。本案法院駁回再審之訴。

一案中⁴¹，被告占有原告未辦理保存登記之房屋長達27年，原告（房屋之出資建造者）要求返還所有物。法院認為被告時效取得房屋所有權，然論理與實務主流見解有異。該案正確的論理方式應該是：原告之所有物返還請求權已經罹於時效（系爭不動產未經登記，故有消滅時效規定之適用；司法院釋字107號、164號解釋參照）。該案判決不由此途，卻引述權利濫用之法理。再者，該案被告在應訴之前根本沒有申請所有權登記，依據最高法院見解，被告

37 福建連江地方法院95年度簡字第3號民事判決。

38 福建連江地方法院94年度訴字第9號民事判決。

39 福建連江地方法院98年度簡字第2號民事判決。

40 福建連江地方法院99年度再易字第3號民事判決。

41 臺灣士林地方法院98年度訴字第389號民事判決。

無法時效取得。因此可知，該案判決被告可時效取得，奠基在多個錯誤的法律論理上。

一案中之占有人於1982年到2008年間占有國有未登記土地，取得土地所有權；此未登記土地在離島金門⁴²。

在篩去論理有問題的判決後，真正依據民法而時效取得所有權者，並非10筆，而是2筆。1筆的時效取得發生在20年前，且2筆都發生在離島。在臺灣本島，以及逐步完成不動產登記的離島，未來還有時效取得所有權之可能？

成功時效取得定限物權的四個案件，三筆關於地上權，論據並無問題。一案中占有人占有國有土地達50餘年，時效取得地上權⁴³。另一案中之占有人占有私人土地數十年後，時效取得地上權⁴⁴。一案中之占有人（廟宇）占有私人土地26年，時效取得地上權⁴⁵。唯一關於不動產役權的案件，其實並非適用民法時效取得之規定，而是法院依據司法院釋字第400號解釋⁴⁶，認定系爭私有土地經長久通行，變成附有「公用地役權」之私有土地。由此可知，時效取得地上權，仍是時效取得制度最常發揮實際作用者。

42 福建金門地方法院99年度簡上字第2號民事判決。請注意本案為上訴案件。

43 臺灣臺南地方法院98年度訴字第975號民事判決。

44 臺灣宜蘭地方法院99年度訴字第301號民事判決。

45 臺灣高雄地方法院98年度重訴字第187號民事判決。

46 臺灣宜蘭地方法院100年度訴字第114號民事判決。

表2 時效取得標的與結果

時效取得標的	是否時效取得		總計
	否	是	
所有權	49	6	55
兩種以上定限物權	2	0	2
地上權	94	3	97
農育權	1	0	1
不動產役權	4	1	5
租賃權	2	0	2
總計	152	10	162

資料來源：本文建構之數據資料庫。本文製表。

表3 不動產類型與時效取得結果

不動產類型	是否時效取得		總計
	否	是	
土地	145	9	154
定著物	7	1	8
總計	152	10	162

資料來源：本文建構之數據資料庫。本文製表。

表4 不動產登記狀態與時效取得結果

系爭不動產 有無被登記	是否時效取得定限物權		總計
	否	是	
未登記	12	1	13
有登記	89	3	92
總計	101	4	105

資料來源：本文建構之數據資料庫。本文製表。

註：本表僅納入定限物權時效取得之案件，因為所有權時效取得依現行法僅限於有登記之不動產。2筆觀察值涉及租賃權之時效取得，與法不合，法院未判斷不動產之登記狀態。

表5 土地類型分佈

土地類型	筆數	百分比
國有公用土地	16	27.6
國有非公用土地	4	6.9
私有土地	38	65.5
總計	58	100.0

資料來源：本文建構之數據資料庫。本文製表。

註：本表僅納入第3部分編碼之觀察值，因為第一輪編碼時並未納入此問題。

表6 (未)時效取得之理由

(未)時效取得之理由	所有權		定限物權	
	筆數	百分比	筆數	百分比
不動產有登記	23	41.8	NA	
沒有所有或取得定限物權之意思	6	10.9	35	32.7
沒有物權意思也沒有申請登記	NA		12	11.2
時間未到	5	9.1	2	1.9
森林地、水利地、原住民地、保護區	6	10.9	2	1.8
不繼續	2	3.6	1	0.9
未申請物權登記	2	3.6	44	41.1
其他原因	5	9.0	7	6.5
成功時效取得	6	10.9	4	3.7
總計	55	100.0	107	100.0

資料來源：本文建構之數據資料庫。本文製表。

二、「取得地上權之意思」之解釋

地方法院不動產時效取得判決最常出現的大問題，是錯誤解釋「取得（或行使⁴⁷）地上權之意思」；本節將剖析實務見解值得商榷處何在。時效取得之基本立法論問題，如：「未登記之土地」是否解釋為「應登記而未登記之土地」（從而排除「毋須登記之土地」）；或占有人在被訴請返還不動產後才申請時效取得財產權登記，法院是否該為實體法之裁判⁴⁸，也在不少地方法院判決成為爭點（學者迭有不同意見⁴⁹）。這些基本問題，留待第參部分一併論

47 惡意占有人因明知自己不是物權人，其意思較適當以「(時效)取得地上權之意思」描述。善意占有人因為自以為是物權人，其意思較適當以「行使地上權之意思」描述。

48 參見謝在全，民法物權論（上），5版，頁219（2010年）。

49 例如，詹森林教授主張，長期占有人符合時效取得地上權之構成要件後，即使占有人於所有人起訴時，仍未向地政機關申請地上權時效取得登記，法院仍應

述。本文所閱讀之上百件案件，還有其他類型之論證瑕疵，但未廣為接受、流傳，在此按下不表。

(一) 學說、實務見解

依現行實務見解，民法第768條、第768條之1、第769條、第770條等四條時效取得條文，均用「以所有之意思」開場，而民法第944條第1項既規定「占有人推定其為以所有之意思，善意、和平、公然及無過失占有」，長期占有人若主張時效取得所有權，不用舉證其有「所有之意思」。表6中6筆「無所有之意思」的案件，都是占有人自承「從來沒有想要占人土地」而破功。

民法第772條規定：「前五條之規定，於所有權以外財產權之取得，準用之。於已登記之不動產，亦同。」依實務見解，時效取得定限物權者，必須具備「以行使地上權（農育權、不動產役權……）之意思」。由於民法未推定占有人有「行使定限物權之意思」，此要件之舉證責任落在長期占有人，也成為許多欲時效取得定限物權者，敗訴之關鍵（參見表6）。

以最常見的「行使地上權之意思」為例，如何證明此種意思，有主觀、客觀兩說。臺灣高雄地方法院98年度重訴字第187號民事判決⁵⁰，對兩說之內容有詳盡之闡述，摘錄如下：所謂客觀說，係

為實體上裁判。參見詹森林（註19），頁42。謝哲勝教授亦認為，時效取得是非因法律行為而取得，登記前即已取得地上權。參見謝哲勝，民法物權，4版，頁278-279（2012年）。

50 該判決採客觀說，對主觀說之批評十分詳盡，摘述如下：「所謂以所有之意思者，此非為法律行為之意思，更無需為取得所有權之意思，其僅需為自己占有其物，且事實上對於占有物具有與所有人為相同支配之地位為已足，而占有人係以何意思占有不動產，此係其內心之意識形態，一般並不須向他人表明，且通常內心意識為何原難以舉證，故法律始對之設有推定，否則即根本無從適用，在占有依法僅推定以所有之意思而無其他權利意思為之情形下，如欲要求準用時效取得所有權規定者須證明法律未規定之推定意思，以意思僅係個人主觀意識之存在，一般人如何對不可能具體化之現實為證明，此根本無從期待，況如占有者係現實上根本即無主觀意識之法人或其他類此組織之本件被告者，

指「苟占有人於占有之始，即有於他人土地上有建築物、工作物、竹木之目的而使用土地，占有後確有建造房屋或工作物或竹木等情事，自與單純之占有使用土地有別，則依該占有所有由發生之事實之性質，自難謂占有人於占有之始無行使地上權之意思，見最高法院85年度台上字第609號裁判意旨」；而主觀說則「主張因時效取得地上權者，依民法第772條準用同法第769條或第770條之規定，須以行使地上權之意思而占有他人之土地，經過一定之期間，始得請求登記為地上權人。此項意思依民法第944條第1項之規定既不在推定之列，故須由占有人負證明之責。又占有人無法律上之權源在他人土地上有建築物或其他工作物或竹木，可能係基於侵權行為之意思，亦可能基於越界建築使用，亦或界址不明致誤認他人土地為自己所有，或因不知為他人土地而誤為占有使用，尚難僅以占有人在他人土地上有建築物或其他工作物或竹木之客觀事實，自認占有人係基於行使地上權之意思而占有，見最高法院87年度台上字第1284號裁判意旨」。(以上粗體為本文所加。)

就本文閱讀所見，地方法院的主流是主觀說（最高行政法院95年9月份庭長法官聯席會議亦採此見解⁵¹）。不少法院認為，長期占

則如法律確係要求占有者之被告為如此之證明，該法律即形同虛設或為不可期待而無存在之必要，且此亦將斷送全體法律之尊嚴及人民對之信賴，在已登記所有人之土地上原已不可能時效取得所有權之情形下，該準用規定以立法者應不可能自為虛設無法適用之法律的前提下，執法之公正法院於此所為之解釋或使用，自不得自限於無可期待之相當適用，或自畫死地而逾越法律所設目的為強人所難，致限制或剝奪人民為立法者經價值判斷後所賦予之權利者，則本類個案如依前開舉證責任分配之一般規則為適用結果，業造成該負舉證責任之當事人為不可期待或明顯產生不公平之情形，且被告於系爭土地之占有亦絕非為無權占用，而可就系爭土地於通常使用所需之保護價值原遠高於百年來其所有權作用應早已受限甚或不存在之迭為取得的原告，以被告就系爭土地並非無權占有，亦非租賃、借貸等情，基於公平正義之要求，法院依上開規定，自應例外依據誠信、公平正義等原則而就被告所負之舉證責任加以減輕，以期使人民信賴法律及公平法院之存在。」

51 最高行政法院95年9月份庭長法官聯席會議決議謂：「又占有土地建築房屋或種植竹木，有以無權占有之意思，有以所有之意思，有以租賃或借貸之意思為之，非必皆以行使地上權之意思而占有，故主張以行使地上權之意思而占有

有人雖有行使所有權之意思，但占有人無法證明其具有時效取得地上權之意思，因而判其敗訴⁵²。有判決則認為，占有土地可能基於各種「意思」，長期占有人必須舉證自己是以「行使地上權之意思」占有⁵³。更有判決指出，長期占有人主張之農育權，「乃係民法物權編於99年2月3日修正施行後所創設之物權，原告自無法於農育權創設前，即以行使農育權之意思而繼續占有系爭土地，更遑論得依民法第769條或依民法第772條準用同法第769條規定，主張以時效取得農育權登記請求權之餘地」⁵⁴。這些判決都採取主觀說。

與實務不同，學者似未有採取主觀說者。有批評實務對「行使地上權意思」之見解⁵⁵，亦有採取類似客觀說者⁵⁶。

者，應負舉證責任；另主張時效取得地上權者，須以行使地上權之意思而占有始足當之，若依其所由發生事實之性質，無行使地上權之意思者，非有變為以行使地上權之意思而占有之情事，其取得時效，不能開始進行。申請人提出之四鄰證明書，尚不足以證明其係本於行使地上權之意思而占有系爭土地，登記機關尚不得依時效取得地上權登記審查要點為公告。」

52 例如：臺灣臺北地方法院97年度訴字第2582號民事判決、臺灣臺北地方法院94年度訴字第2050號民事判決、臺灣高雄地方法院98年度訴字第281號民事判決。

53 例如：臺灣基隆地方法院96年度訴字第30號民事判決，該判決主張：「地上權之時效取得，以行使地上權之意思占有土地為要件，而房屋建築經土地所有人同意者，樣態不一而足，或基於使用借貸、或基於租地建物、或基於合建、或基於地上權之設定等，故建物所有人非必基於行使地上權之意思而占用土地；如主張以行使地上權之意思占有者，應負舉證責任（最高法院64年度臺上字第2204號、84年度臺上字第748號判決要旨參照）……況地上權人以給付地租為原則，被告未提出曾給付土地所有人地租之證明，更難謂其以行使地上權之意思占有系爭土地。」

54 臺灣臺東地方法院100年度東簡字第34號民事判決。

匿名審查人指出，依據民法物權編施行法第13條之2第3項，永佃權人得請求變更登記為農育權。依據民法第945條第1、3項，修法新增農育權，可以視作「新事實」而變更占有之占有意思。此為前述判決未慮及之處。

55 謝哲勝教授批評：「以所有的意思為[時效取得地上權]要件是合理的，因為，所有的概念是一般有思慮能力的人所具備的，然而一般人並無地上權的概念，大部份占有人既然都不懂地上權為何物，怎可能以行使地上權的意思而占有，規定此要件，毋寧是變相強迫占有人說謊。而舉證責任之所在，敗訴之所在，占有人本不具有此意思，此又為主觀意思，要求其證明，實在有其困難。占有人於占有物上行使的權利，推定其適法有此權利……除客觀上推定其適法有此

（二）自主占有、他主占有、時效取得問題中之占有

通說認為，「以所有之意思」就是自主占有。通說又將自主占有與他主占有對舉，認為他主占有乃「不以所有之意思而占有」⁵⁷，或「以占有媒介關係而占有他人之物」⁵⁸。然而，自主與他主占有的二分定義方式，使得「明知並以（時效）取得地上權之意思」而占有者，無法被論為自主占有，只能被歸入他主占有。但學說所舉他主占有之例，是為說明因意定之定限物權或契約而用益，未有學說明白主張，有意時效取得定限物權之占有人乃他主占有人。是故，問題厥為，有意時效取得定限物權之占有人，如何定位？

本文認為，依據民法條文的二分法，是「以所有之意思」和「無所有（之）意思」（後者參見民法第945、956條文字）。但民法條文並沒有自限於二分法，民法第945條第3項使用「（不同之）其他意思而占有」，參照該條文字可知，立法者應認為占有意思有大於兩種的可能分類。

可以依照通說見解，將「自主占有」和「以所有意思占有」劃上等號。但「無所有（之）意思」卻可能包括多種意思，不宜以「他主占有」概括。他主占有，顧名思義，適合指涉「未有貳心」的承租人與定限物權人——占有某物，但以他人為主人。但至少對於惡意占有他人不動產，有意時效取得地上權、農育權等定限物權者，其占有該物，並非以他人為主人。概念上不適合將此等惡意時效取得人與前述典型他主占有人混為一談。

權利，主觀上應也推定其具有行使此權利的意思。」參見謝哲勝，時效取得（註16），頁62-63。

56 謝在全教授認為，行使地上權之意思，「非僅依占有人之內心意思定之，而係依占有所有由發生之事實（取得占有之原因）之客觀性質，亦即占有人對占有土地所為事實支配之外形客觀狀態決之」。參見謝在全（註8），頁174。

57 參見謝在全，民法物權論（下），5版，頁472（2010年）。

58 參見王澤鑑（註25），頁548。

釐清了自主占有、他主占有與有意時效取得定限物權而占有後，進一步闡述自主占有與「以所有之意思……占有他人之不動產」之區別。自主占有，或「以所有意思占有」，包括三種狀況中之某甲：

(1) 狀況A：某甲是所有人，占有甲之地，認識到自己是所有人。

(2) 狀況B：某乙是所有人，某甲明知其事卻以所有人自居，占有乙之地，希冀透過時效取得制度成為所有人。惡意之某甲為「明知非所有人」。

(3) 狀況C：某乙是所有人，某甲誤以為自己是所有人，並占有乙之地。此即「誤信為所有人」⁵⁹。

學理之自主占有，包括A、B、C三種狀況。狀況A是「以所有之意思占有『自己』之物」，與狀況B、C描述之「以所有之意思占有『他人』之物」，有所不同。時效取得問題中之占有，並不包括狀況A。民法第768條至第770條，適當的斷句方式是「以所有之意思……占有他人」之（不）動產。也就是說，「以所有之意思」不應該被斷章取義，條文有強調「占有『他人』之物」。是故，本文後續論述中，並不會使用自主占有之概念，以指涉民法第768條至第770條所要求之占有。

更進一步說，雖然狀況B描述之要素，基本已經完備了民法第769條對惡意時效取得所有權人「以所有之意思……占有他人」不動產之要求；狀況C卻尚未充分滿足民法第770條對善意時效取得所有權人「以所有之意思……占有他人」不動產之要求。民法第770條對善意之要求僅限於占有之始善意，但從本文閱讀之判決可推

⁵⁹ 參見王澤鑑（註25），頁548。

知，不少占有人直到數十年後被真正所有權要求離去，才驚覺自己原來占了別人的地。（其長期無權占有之無知狀況，是否無過失，屬另一問題；因該條並不要求占有中持續無過失，法院並未深究此問題。）善意占有人雖然一直以所有人自居，但直到訴訟中才第一次面對「我要不要透過時效取得別人財產」的大哉問。

民法第770條假想的善意占有人，是占有之始善意無過失，然後超過十年後有一天突然發現自己沒有所有權，但已經可以時效取得。不想奪人財產者，就默默打包離開。不甘辛苦付諸流水者，就依該條「請求登記為所有人」。善意占有人既然已經提出時效取得登記，則通常就是有意透過時效取得別人財產⁶⁰。但尚未提出登記申請就被告的占有人，要在訴訟中回答前述大哉問。

如果占有人給了否定答案，不願意橫奪他人不動產，則不具備民法第770條之要件。所以，狀況C可以分成C1和C2兩種狀況：C1是善意占有人以所有人自居，發現自己無權占有後，仍然想要成為所有人。C2是善意占有人以所有人自居，發現自己無權占有後，揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。由表6可知，確實有善意占有人雖然一直以所有人自居，但在訴訟中若確知自己沒有權利，即表示不願透過時效取得獲得他人財產權。依民法第770條所為之時效取得，只限於C1。

60 土地登記規則第118條第1項規定：「土地總登記後，因主張時效完成申請地上權登記時，應提出以行使地上權意思而占有之證明文件及占有土地四鄰證明或其他足資證明開始占有至申請登記時繼續占有事實之文件。」依照本文見解，該條要求之文件，就是（1）足以證明「占有之公然使用方式，如同地上權人」之文件，例如占有期間建築房屋之證明文件；及（2）占有人以切結書聲明自己有意取得他人土地上財產權。關於單純取得或喪失占有，不需要占有心素；但透過取得或喪失占有而取得或喪失物權，必須具備占有心素（在此為「透過占有取得他人土地上之地上權之意圖」），參見Yun-chien Chang, *The Economy of Concept and Possession, in LAW AND ECONOMICS OF POSSESSION* 103, 113 (Yun-chien Chang ed., 2015)。此即為何登記機關需透過切結書確知占有人在申請登記時有此取得物權之意圖。

C1和C2之區分，更可以看出為何有必要區辨自主占有與時效取得制度所要求之占有。某些善意占有人可以十年中都為自己占有、以所有人自居，但不願意橫奪他人財產（C2）。即使我國法由「請求登記為所有人制」改為「時效完成當然成為所有人制」，此種善意占有人（C2）都不應論為可以時效取得所有權，因其缺乏取得物權必要之意圖。

（三）取得地上權意思之認定

時效取得地上權之意思認定，與時效取得所有權之意思認定，有共通之處。此即民法第772條準用民法第769條、第770條之故。「以（行使或取得）地上權意思而占有」，同樣可以分為三類，適用到下列之某丙。

（1）狀況X：某丙是地上權人，占有丁之地，某丙認識到自己是地上權人。

（2）狀況Y：某丁是所有人，某丙明知丁並未設定地上權給自己，卻以地上權人自居，占有丁之地，希冀透過時效取得制度成為地上權人。

（3）狀況Z：某丁是所有人，某丙誤以為自己是丁土地上之合法地上權人，並占有丁之地。

狀況X中之某丙，其意思更精確地描述是「以行使地上權之意思而占有他人土地」，乃他主占有之一種，以下無須討論。

狀況Y中之某丙，其意思更精確地描述是「以『取得』地上權之意思而占有他人土地」。

狀況Z中之某丙，是「以行使地上權之意思而占有他人土地」，但在訴訟中面對法官之大哉問，則等於是要回答：「如果早知道土地為他人所有，是否會以取得地上權之意思而占有？」這種假設問

題其實又等於：「占有人現在是否有意願取得他人土地上之地上權？」若占有人給肯定答案，稱為狀況Z1。

如此分析起來，民法第772條準用前幾條之結果，在占有意思上就是要求狀況Y和狀況Z1。實務上的爭議與誤解，究竟何來？多數法院為何要採取主觀說？本文推測，實務應係出於兩種考量：第一，想藉由占有之舉證，確定其能取得者為地上權、農育權、或其他財產權。第二，擔心有占有人，沒有取得財產權之意思，而只是基於侵權行為意思而占有，直到被要求返還土地才主張要時效取得者」。法院因為不知如何分辨孰為此種占有人，於是要求占有人舉證。

1. 採客觀說判決定限物權類型

但要解決前述兩種問題，並不一定須採取主觀說。主觀說要求占有人有債、物二分之觀念，知道除了租賃、還有地上權，在占有期間都明瞭所有權、地上權、農育權等財產權之差異。但從時效取得制度之理論基礎出發（參見本文第參部份之討論），沒有道理以占有人的法律知識作為是否保障其占有之前提要件。民法第772條準用第769條與第770條，並不是為了要求時效取得定限物權人具備法律知識，可以分辨各種定限物權，並以某一種定限物權之意思而占有。毋寧，民法第772條之準用，如前所論，只是要確認狀況Y或狀況Z1存在。

要確認這兩種狀況存在，主觀說與客觀說各有利弊。筆者雖不贊成將時效取得制度適用於已登記之不動產（參見本文參、二），但在現行法框架下，實務主觀說無端在「取得或行使地上權意思」之要件上，讓長期占有人無法時效取得，與時效取得制度整體之價值判斷有間。要求占有人說明其占有意思，固然可避免下述客觀說之操作結果可能偏離占有人真意之弊；但占有人除了以客觀事實說明其占有意思，又能如何舉證，而不落入前述主觀說之流弊？兩相

權衡，客觀說有其簡便之功。

依照客觀說，要解決實務上的「判斷物權類型」、「確認占有人意圖」這兩個問題，以客觀說之「占有所由發生之事實之性質」，即已足夠——換言之，就是以占有期間公然使用系爭不動產之方式來判斷。只有在善意時效取得之情形，法院須多問占有人一句話，確認其在訴訟當時是否有意願取得他人土地上之權利。

2. 精確言之，以公然使用方式為斷

如何以占有已登記不動產期間之公然使用方式⁶¹，判斷占有人能取得之財產權種類？若為建屋，時效取得普通地上權；若為種植竹木，時效取得農育權；若有表見與繼續之通行，只能取得通行不動產役權⁶²。

或有質疑，典權人、承租人、借貸人、不動產役權人也可能建屋，何以長期無權占有人建屋，必定認定為時效取得普通地上權？本文之回應是，民法中關於在他人土地上有建築物之規範，以普通地上權最為詳盡與周全。占有人與所有人走到以時效取得解決私權糾紛，必然表示兩造無法磋商出一個私了的法子。若將時效取得之客體認定為普通地上權以外之財產權，兩造間在其他方面既無約定，也無詳細法定方式，徒增困擾。普通地上權對於日後可否、如何拋棄定限物權（參見民法第835條）；法院裁判之地租太低，土地所有權人能否要求調整（參見民法第835條之1）；地上權消滅時，地上物歸誰（參見民法第839條），皆有詳細規定。

相對之下，解釋為其他財產權，均有缺點：

61 採取類似之客觀說之詳盡分析，參見謝在全，地上權短期取得時效完成之效力——最高法院九六年度台上字第二三三號判決評釋，台灣法學雜誌，132期，頁84（2009年）。

62 個案中到底是時效取得何種財產權，涉及很多事實與解釋，是第一線的法官最重要的判斷工作。See JOSEPH WILLIAM SINGER, PROPERTY 146 (3d ed. 2010).

(1) 租賃之緣由因不限於租地建屋，債編租賃章之相關規定，就沒有地上權這麼完備。

(2) 不動產役權雖準用了許多地上權之規定（民法第859條之1與第859條之2參照），但不動產役權的類型眾多、用途紛雜，而地上權本質上就是一種特定之役權——民法第838條規定地上權與地上物不得分離而讓與，使地上權等同於「他人土地供自己地上物座落（特定便宜）之用」。就使用他人土地安置地上物而言，地上權之規定就像是不動產役權規定之「特別法」，在時效取得規定適用時，應優先適用地上權規定。

(3) 若解釋為除了金門、馬祖幾乎沒有被使用的典權，時間到了原所有權人還要付錢給時效取得典權者才能「回贖」，賠了夫人又折兵，很不合理。就算法院在判決時效取得典權時，酌定典價，要求時效取得者支付給土地所有權人，但典權式微，典價酌定勢必流於臆測。又何必硬要認定占有人是有意取得典權？

(4) 就算可以時效取得使用借貸權，因為時效取得之借貸無確定借貸期限，也難以認定借貸之目的為何，依民法第470條，不動產所有人（時效取得使用借貸關係中的貸與人）可以隨時請求返還，時效取得並無意義。而若採其他見解，使時效取得之借貸可以長期持續，因使用借貸為無償，對不動產所有人太過不公平，也無效率（如下詳論）。司法院釋字第291號解釋揭示了時效取得地上權者，必須支付地租。若解釋為時效取得借貸權，毋庸支付地租，則有違前揭憲法解釋之意旨。

若時效取得之緣由是當事人間本有典權、租賃、不動產役權關係，事後被發現無效或被撤銷，則以該權利作為時效取得之客體，尚有合理之處⁶³（但這種教科書的例子到底在現實世界多常發生？

63 有學者認為，要時效取得「以支付一定對價為成立要件之財產權」，如租賃與

本文前述抽樣之判決，沒有任何案件是這種原因事實……)。但若占有人是單純無權占有，似仍以解釋為時效取得地上權，較為務實、簡便，且能適當平衡土地所有人和時效取得定限物權者之利益。

誠然，照本文闡釋之客觀說，法院操作時效取得條文之結果，可能給予占有人不同於其真意之定限物權。但再一次強調，許多占有人在十幾二十年的占有期間，根本意思不明。占有人確定的意思是「我想用這塊地」，但是究竟是以承租人、典權人、地上權人、借貸人……的身分地位為之，絕大多數沒有法律訓練的占有人根本沒想過這個問題。若按照主觀說，這些占有人除非說謊，否則難以通過主觀說的構成要件。但時效取得的基本理論，從沒有將占有人通透物權法作為必要條件，也沒有必要如此。果爾，客觀說仍較主觀說為當。

3. 物權類型以占有人主張時效取得時之法律為準

占有之公然使用方式，必須符合訴訟當時有效之法律所定之物權要件。試舉三例：(1) 某庚明知某地為某辛所有，以取得地上權之意思，20年間不間斷地種植竹木。在2015年申請時效取得地上權與農育權之登記。在前述主觀說之下，某庚兩種登記都該被駁回。依本文見解，某庚可時效取得農育權。(2) 占有人某庚若以某辛土地供不特定人臨時停車，但沒有建造任何工作物，即無法時效取得地上權、農育權，因為該占有之行為就不像地上權人或農育權人。而除非占有人在系爭不動產附近有自有不動產，否則不能成立不動產役權。(3) 假設某庚佔據滿佈果樹之肥沃土地，沒有種新樹、也沒有施肥翻土，只有每年結果時坐收漁翁之利，對此土地別無其他利用。外國法上雖有此等物權（如英美普通法之*profit à*

典權，以占有人曾有交易為當。參見謝在全（註8），頁172。

prendre，一種人役權⁶⁴，或許可依照民法第70條用語翻譯成「天然孳息收取權」，但該條之權應僅為依契約所生之債權），但依臺灣現行法，某庚無法取得定限物權，因為無此類型！

法院要判斷占有人是「基於侵權行為意思而占有」，還是有意取得地上權，也是取決於公然使用方式。想取得地上權者，比起路人、過客、搗蛋鬼（所謂「基於侵權行為意思而占有」），其「行為表現⁶⁵」必然不同——他會顧長線，不會只炒短線；會珍惜地利，不會殺雞取卵。占有人不需證明自己從有充足之物權法知識，只要舉證他使用系爭不動產之方式，如同一般合理普通地上權人即可。

4. 占有意思轉換

最後，須強調者，本文對民法第769、770、772條之解釋，不排除第945條規定之適用。第945條是本文少數持肯定態度的占有相關條文。該條之通知，一方面使所有人知悉占有人的「不良居心」，從而可有行使返還權利之機會；另一方面也可作為時效取得之起算點。若占有人可以不通知就轉換占有意思，使所有人在多年後被時效取得才得知占有之狼子野心，必然增加全體所有人探查占有人心態之誘因。此種時時探查，成本很高；但要求轉換占有意思之占有人通知所有人，頻率甚低、成本亦低。很明顯地，第945條之規定符合經濟效率。有學者主張，占有人在占有土地之始，即需將取得地上權之意思表示於外部⁶⁶。本文則認為，占有人僅須依第945條之規定，將轉換占有意思表示於外部。若依第945條毋庸通

64 See THOMAS W. MERRILL & HENRY E. SMITH, PROPERTY: PRINCIPLES AND POLICIES 987-88 (2d ed. 2012).

65 在時效取得所有權之情境，美國文獻會強調占有人必須「表現得像個所有人」（act like an owner）。See, e.g., JAMES E. KRIER, PROPERTY 29 (17th ed. 2006). 並參見註169所引文獻及相關論述。在時效取得定限物權時，也要有類似表現。

66 參見陳立夫，土地法研究（二）（註5），頁61。對此見解之質疑，參見謝在全（註61），頁85。

知，占有人無須在占有之始就表達其占有意思，否則善意占有人幾無時效取得之可能⁶⁷。

(四) 舉證責任歸屬

「以取得地上權之意思」而占有他人土地，應該由占有人舉證？學說、實務認為民法第768條到第770條之「以所有之意思」乃獨立要件，與自主占有同義；因此，基於民法第944條第1項規定，「占有人推定其為以所有之意思，善意、和平、公然及無過失占有」，欲時效取得所有權者，毋庸負擔「以所有意思」之舉證責任。反之，因為民法第944條第1項沒有推定「以取得定限物權意思而占有」，主張時效取得定限物權者負擔舉證責任。此種差別待遇，讓時效取得定限物權者，比時效取得所有權者，更不容易舉證，很難想像是立法者本意，亦不合理。不過，本文同意主張時效取得定限物權者負擔舉證責任，而主張時效取得所有權者，也同樣應該舉證所有要件。故本小節要挑戰者乃民法第944條第1項根本制度目的。

民法第944條第1項將「一般無權占有之推定」與「為時效取得而占有之推定」，冶於一爐，且價值判斷值得商榷。民法第944條第1項之「和平、公然」似僅與時效取得有關，不應置於占有章⁶⁸。即令移入時效取得相關條文，是否應推定為和平占有與公然占有，使土地所有人負反證推翻之責，仍有再商榷餘地——本文不理解給予時效取得人此種舉證優待的政策目的為何。

67 占有人在占有土地之始，即需將取得地上權之意思表示於外部，會使惡意占有人容易被所有人發現，從而難以時效取得。從政策觀點，本文完全贊成讓惡意占有人不能時效取得，但如本文第參部份所論，此種結果只要透過禁止惡意占有人時效取得不動產物權制度，並推定不動產占有人為惡意，即可達到。

68 此外，民法第944條第2項之繼續占有規定，民法第945條轉換占有心態之規定，也只與時效取得有關，應該移到時效取得條文處（如考慮增訂民法第770條之1）。

民法第944條第1項之「善意、無過失」占有規定⁶⁹，適用於民法第952條至第958條之「所有人與占有人之返還關係」⁷⁰，亦可適用於善意取得與時效取得問題。但各種占有問題中，是否該一律推定占有人善意且無過失，需要逐一檢討。在此，本文僅質疑在不動產物權時效取得問題中，將占有人推定為善意、無過失之合理性。以時效取得問題中之占有推定而言，一般無權占有應區分兩類：（1）以臺灣土地登記制度與其他登記制度之發達，相關地籍資訊取得之易，不動產及有登記動產之無權占有人，應該推定為惡意，或至少要推定為善意但有過失（即可得而知）⁷¹。（2）占有未登記動產則可推定為善意。

試想，無權占有已登記地上物者，依民法第943條第2項第1款沒有被推定為適法有權行使權利，為何依民法第944條要推定為善意、無過失占有⁷²？要維持土地登記簿之公信力，促使不動產使用者多利用土地登記資訊，就不應推定已登記土地之占有人善意且無過失。難道是否擁有某棟地上物，不是任何神智清楚的人都應該知道？受到一般教育的臺灣民眾難道不知道有地政機關可以查詢土地產權狀態？一律將時效取得問題中之無權占有人推定為善意、無過

69 解釋上，民法第944條第1項之推定不及於有權占有。否則，土地承租人為何要被推定為以所有之意思占有？借貸土地者不公然占有又礙著誰？

70 依照學者見解，民法第952條至第958條之適用，本以占有人為無權占有為前提。參見鄭冠宇，民法物權，3版，頁222-223（2013年）。故為適用民法第952條至第958條，毋須對有權占有人作任何事實推定。

71 如前所論，未登記土地幾乎要絕跡了；而僅有的未登記土地與未登記定著物，都難以想像有許多真正善意的占有人，故一律推定為惡意。或許可以仍一律推定為善意，但容許主張者（通常為所有人）輕鬆舉證系爭物為不動產或有登記之動產而推翻善意推定。但本文擔心實務上或許不會允許這麼簡單的反證，因為過度限制了推翻善意推定之空間。

72 最高法院96年度台上字第2303號判決（其評釋參見謝在全（註61），頁81-91）中，占有人宜蘭縣某市市公所占已有登記土地，但確實可以被認定為善意且無過失。不過，本文主張是這種情況應該是少數。縱依本文見解，將全部已登記土地之占有人都推定為惡意，本案中之占有人仍可以舉反證推翻。

失占有，應有再商榷餘地⁷³。民法第943條之價值判斷較民法第944條第1項更合理。

最後，無論是在時效取得問題中或其他占有問題中，民法第944條第1項一律推定無權占有人為「以所有之意思」占有，此種立法政策之道理何在，本文亦摸不著頭緒。（若推定無權占有人是以侵權行為之意思而占有，又有何不對？）物權法的原則是保護物權人，時效取得制度是物權法中非常例外的規定（詳後，時效取得既不是財產原則，也不是補償原則），有意利用例外的時效取得制度者，應該負擔舉證責任，才能儘量維持物權法的原則。只要實務能參照本文論述，正確理解何謂「以所有之意思……占有他人之物」，即令無此推定，真正的時效取得人仍可舉反證推翻。

不推定自主占有之見解，確實有降低時效取得成功率之效果；基於本文第參部分詳述之見解，限縮時效取得制度之適用，有助於提升效率。

參、建構新時效取得制度

本部分由更宏觀的立法論觀點，與法律經濟分析方法，嘗試建構當下臺灣應該採取之時效取得制度。時效取得制度既沒有採用物權法慣用之「財產原則」（the property rule）⁷⁴，也沒有採用「補償

73 學者有批評民法第944條第1項之推定，不分青紅皂白，過於寬泛——例如將地上權人之占有也推定為以所有之意思。參見張永健，占有規範之法理分析，臺大法學論叢，42卷特刊，頁883-884（2013年）。

74 關於物權法慣用財產原則，see, e.g., Henry E. Smith, *Property and Property Rules*, 79 N.Y.U. L. REV. 1719, 1722 (2004); Richard A. Epstein, *A Clear View of the Cathedral: The Dominance of Property Rules*, 106 YALE L.J. 2091, 2092 (1997); Richard R.W. Brooks, *The Relative Burden of Determining Property Rules and Liability Rules: Broken Elevators in the Cathedral*, 97 NW. U. L. REV. 267, 311 (2002); Robert C. Ellickson, *Adverse Possession and Perpetuities Law: Two Dents in the*

原則」(the liability rule)⁷⁵，而是直接將產權(entitlement)由原所有人劃歸占有人，且不要求占有人支付原所有人對價⁷⁶。沒有任何其他物權法規定，採用此種產權劃歸與保護模式。為何要採取這種特殊制度？羅馬人應該有他們的道理。但本文預設的立論對象與情境，是21世紀的臺灣，有些論據適用於羅馬帝國、中世紀歐洲、當代美國⁷⁷，但不適合用於臺灣，本文就不一一檢討。本部分的論據

Libertarian Model of Property Rights, 64 WASH. U. L. Q. 723 (1986); Carol M. Rose, *The Shadow of the Cathedral*, 106 YALE L.J. 2175 (1997).

- 75 關於補償原則與財產原則之定義，中文文獻：王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理——從一則土地相鄰關係的判決談起，收於：民商法理論與經濟分析，頁143-144（2000年）；葉俊榮，出賣環境權，收於：環境政策與法律，頁56-58（2010年）；簡資修，一物二賣：有效率之不履約或債權之侵害，人文及社會科學集刊，13卷1期，頁65-88（2001年）。英文文獻：開山之作，see Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, 85 HARV. L. REV. 1089, 1105 (1972). 近年來影響力最大的集大成之作，see IAN AYRES, *OPTIONAL LAW: THE STRUCTURE OF LEGAL ENTITLEMENTS* (2005).
- 76 在時效取得地上權之情境，大法官解釋要求時效取得人支付地租。但此種地租是否在實踐中有達到市場行情，有待進一步研究。
- 77 舉例而言，美國學者有主張，時效取得制度可以「清理土地登記資料，並剔除古老的請求權」。See THOMAS W. MERRILL & HENRY E. SMITH, *THE OXFORD INTRODUCTIONS TO U.S. LAW: PROPERTY* 37-38 (2010); Richard A. Epstein, *Past and Future: The Temporal Dimension in the Law of Property*, 64 WASH. U. L. Q. 667, 678 (1986); Thomas W. Merrill, *Property Rules, Liability Rules, and Adverse Possession*, 79 NW. U. L. REV. 1122, 1128-31 (1984); Jeffry M. Netter et al., *An Economic Analysis of Adverse Possession Statutes*, 6(2) INT'L. REV. L. ECON. 217, 219 (1986). 然而，「清理土地登記資料」只有在採用「契據登記制」處（如美國大多數州）有意義。在契據登載制下，登記機關只是蒐集物權交易契約，並加上索引，並不負責審查登記之內容，或整理各筆土地、建物之權利狀態。所以，久不久來一次時效取得（性質為原始取得），可以讓之後作「權利追索」(title search)的交易者，節省勞力費用——只要追索到一次原始取得即可停止，不用再往前追索祖宗八代之交易，因為權利狀態由該次原始取得開始新的權利秩序。而在權利登載制之下，時效取得和買賣交易一樣，都只是一筆登記紀錄，對於後手之資訊成本毫無影響。此外，臺灣物權法沒有「未來利益」(future interests)——例如像是美國普通法中搭配「終生地產權」(life estate)的「剩餘財產所有權」(remainder)——不會有綿延數十年、懸宕不決的物權（所以美國普通法才要有rules against perpetuities），所以不需要藉由時效取得此種原始取得來剔除源自於未來利益的古老請求權。其他與契據登記制有關但和權利登載制無關的論據，see, e.g., Jeffery Evans Stake, *The Uneasy Case for Adverse*

與鋪陳方式，是為了打掉現制，重建新思維；但核心論據也可用以支持或批評現行的法律規定、學說見解、實務作法。

第一節先回顧對臺灣建置新時效取得制度最有可能有參考價值之三種理論，但本文指出「權利睡著理論」與「損失厭惡理論」的論理缺陷，以及「有效率侵害理論」之適用侷限。第二節依據有登記、未登記土地、定著物，占有人是惡意、可得而知之善意、無過失之善意為經緯，逐一檢討在各種情境中時效取得制度存在之必要與建立制度細節之方向。

一、既有三種理論回顧與檢討⁷⁸

值得先予敘明者，本節所回顧之三種理論，並非全無道理，但提出論據之學者往往並未區辨此理論所適用之範圍、對象、情境，而是概稱為時效取得理論。本文之回應與批評，也不是全面的；亦即，本文之批評在特定情境中的時效取得問題，可能不具有完全的說服力。本節之功用在於點出既有理論之侷限，故從多方面映照，希望能儘量凸顯既有理論之不足。在下一節中，再行建構本文理論與建議制度。

(一) 權利睡著理論

最常見的論據，乃時效取得制度在於懲罰懶惰的原所有人，並

Possession, 89 GEO. L.J. 2419, 2439, 2449 (2001). 將remainder翻譯成「剩餘財產所有權」，參見楊崇森，*遨遊美國法I：美國法之源流與民刑法之運作*，頁272（2014年）。但請注意，有美國學者指出，美國許多時效取得案件都是越界建築，和釐清老舊請求權無關。See SINGER, *supra* note 62, at 156.

⁷⁸ 既有學說整理，參見謝哲勝（註49），頁121（包括：（一）法律幫助勤勉人，不幫助睡眠人；（二）憲法扶植自行使用土地人的政策（憲法第143條）；（三）利用權優於所有權；（四）日本及美國立法例；（五）土地使用效率考量）。時效取得制度存在理由，有實體法說與訴訟法說之別，參見謝在全（註48），頁225-226註2；周武榮，時效取得制度之存在理由及其對於時效取得制度要件及效力之影響，國立政治大學法律學系碩士論文，頁193-194註1（1996年）。

獎賞辛勤的所有者且保護其信賴利益⁷⁹；或可稱為「權利睡著理論」。但此論據並無說服力。

1. 懲罰懶惰？

懲罰懶惰理論的內涵不一，有認為是指懲罰所有人未在法定時效期間內驅逐無權占有人⁸⁰，有認為實際上是逼使所有人出面，讓占有人知道其身分，使占有人能與所有人交易⁸¹。後者在臺灣情境中並無說服力，因為任何人均可輕易由土地所在位置查出地號，並查出登記名義人之登記地址⁸²，不需要大費周章無權占有多年，只為見到登記名義人一面。

前者之直接意涵是所有人行使其所有物返還請求權近似義務，未盡義務者，剝奪其所有權。但何以要求所有人積極行使其物上請求權？剝奪所有權顯然只是手段，迫使其行使物上請求權也只像手段。目的為何？懲罰懶惰理論隱含的應然目的是：促使所有人自行開發不動產⁸³。但若促進開發果真是目的，時效取得制度是很差的手段。所有人要避免時效取得發生，不一定非要開發，只要時時監管、驅逐無權占有人即可⁸⁴。空地稅、空屋稅同樣也有促進開發之效果⁸⁵，而對於某些地主而言，年年都要繳、逃不掉的稅捐，或許更有敦促之效。但是，若系爭土地之最佳利用是（暫）不開發，其

79 此理論之內容，*see* MERRILL & SMITH, *supra* note 77, at 37-38; Merrill, *supra* note 77, at 1128-31; Netter et al., *supra* note 77, at 219.

80 *See* MERRILL & SMITH, *supra* note 77, at 37.

81 *See* Merrill, *supra* note 77, at 1130-31.

82 依照2014年12月生效的新土地登記規則第24條之1，除非登記名義人請求，否則任何人都可以在申請到的第二類謄本上查到登記地址。

83 若要藉由時效取得制度之許諾，而誘使（惡意）無權占有人開發不動產，也成效難期。在真正時效取得所有權之前，占有人不敢以最適規模開發，以免被所有人驅逐，血本無歸。而且，如下所論，惡意無權占有人最可能增進效率的作為是與所有人協商。

84 *See* Stake, *supra* note 77, at 2436.

85 參見蘇永欽（註5），頁47。

所有人卻因為擔憂被他人時效取得或被課空地稅而被迫開發，並無效率⁸⁶。

再者，為何要促使所有人開發？難道理性自利的所有人會因為缺乏資訊而不開發嗎？臺灣地狹人稠，房地產市場之競爭會使得絕大多數的不動產所有人明確感受不開發的機會成本（例如：開發商會捧現金收購土地；隔壁老王將土地出租大賺一筆；新聞鎮日報導地價屢創新高）。所有人按兵不動，可能是著眼於未來的商機，或導因於與眾不同的價值觀——例如，所有人可能是保育人士，收購土地就是為了不開發⁸⁷；對他而言，維持濕地荒蕪遠比破壞水土保持後興建高樓有價值⁸⁸（亦即，所有人是有意識地選擇睡著⁸⁹）。

總之，縱令權利睡著理論有其說服力，並不在懲罰懶惰之部分，而或許是在獎勵勤勞之部分，下一小節探討之。

2. 天道酬勤？

占有者固然辛勤，但惡意占有者本來可以透過自願交易與所有人締結物上或契約利用關係，就可以合法收割其辛勤。時效取得既非必要、也非最佳之保護方式。善意占有人不知道自己無權占有，但在系爭不動產有登記時，其善意與「信賴」若值得保護⁹⁰，則公

⁸⁶ See Stake, *supra* note 77, at 2433.

⁸⁷ 私人保育土地之法律工具，參見陳仲嶙，為環境信託開啟新視野——論私部門從事土地保育的法律工具類型，科技法學評論，9卷3期，頁45-96（2012年）。

⁸⁸ See generally John G. Sprankling, *An Environmental Critique of Adverse Possession*, 79 CORNELL L. REV. 816 (1994). See also Alexandra B. Klass, *Adverse Possession and Conservation: Expanding Traditional Notions of Use and Possession*, 77 U. COLO. L. REV. 283, 292-94 (2006).

⁸⁹ 或許莊子的一段話也可作為註腳：「人皆知有用之用，而莫知無用之用也」。莊子·人間世，請參見漢川草廬，諸子類，<http://www.sidneyluo.net/d/04.htm>（最後瀏覽日：2016年2月24日）。

⁹⁰ 關於善意時效取得人之信賴利益值得保護，see Thomas J. Miceli & C. F. Sirmans, *An Economic Theory of Adverse Possession*, 15(2) INT'L. REV. L. ECON. 161, 161 (1995).

信原則蕩然無存⁹¹。再者，若已登記不動產還會被時效取得，將增加交易者之調查成本，也浪費了登記制度之鉅額費用⁹²。占有人之辛勤若與上述考量一併斟酌，並非可以當然壓倒一切的王牌。

在系爭不動產未登記時，土地登記簿不會有該不動產之資訊。物權歸屬無法由土地登記簿得知，不代表不動產無主。依土地法第10條第2項⁹³，土地不是私有就是國有，不會有無主地；依法地上物不一定要辦保存登記。換言之，不動產有沒有登記和有沒有人所有是不同的問題。惡意占有人只要知道自己不是所有人，不管是否能查知所有權歸屬，至少都有另謀他處的選項。

善意占有人真心認為自己是所有人，但民法為何要保障其因不知法律或弄錯事實而來之信賴（其實更應該稱為誤解）？稍微更有道理的論據是，要保護善意占有人在占有期間之投資。但保護投資或獎勵辛勤不當然要讓占有人無償取得所有權或定限物權（更佳方案，詳後論）。絕大多數資源的擁有者（或其被繼承人），都也辛勤工作，但也都為了獲取資源付出過代價（通常是市場價格）；那為何獨獨時效取得所有權者可以取得免費資源？尤其時效取得地上權者必須支付地租，何以僅因占有人意思之不同，而大異其處理模式？這也是學者會提倡使用「補償原則」（liability rule）規範時效取得之原因⁹⁴。

91 如Judge Richard Posner所論，現代社會之所以由「占有」改用「登記」作為確立不動產權利內容與範圍之方法，就是為了降低社會成本、增進社會福利——占有是事實上管領力，可能時有變動，而資源多者可能光是保持管領力就分身乏術，遑論投資、開發、利用其資源。是故，要求不動產所有人必須積極防衛其產權，則不啻又從較有效率的登記路線，重回較無效率的占有路線。See Richard A. Posner, *Savigny, Holmes, and the Law and Economics of Possession*, 86 VA. L. REV. 535, 561 (2000).

92 參見蘇永欽（註5），頁48。也因此，比較法上較不傾向承認已登記不動產之時效取得。參見蘇永欽（註5），頁47。

93 土地法第10條第2項：「私有土地之所有權消滅者，為國有土地。」

94 See generally Merrill, *supra* note 77, at 1145-54.

3. 變形：配置效率理論

權利睡著理論可以轉換成「配置效率（allocative efficiency）理論」：之所以承認時效取得，是因為長期占有人比原所有人更能利用系爭物；因此，時效取得制度將產權由原所有人手中流轉至占有人手中，可以提升配置效率⁹⁵。

所謂的「更能利用某物」，從經濟分析觀點就是能用某物創造更多產值。但一塊帆布兩畫家相爭，到底帆布歸在誰的手裡能創造出售價較高的名畫⁹⁶？畫作還沒動筆，產值就還在未定之天。客觀第三人能夠仰賴的，只有兩位畫家對自己畫作的產值預估。為免預估灌水，經濟分析理論通常以畫家的出價為準——預估自己畫作會越值錢的畫家，願意出越多錢買帆布⁹⁷。價高者得，得者就被認為是更能利用帆布者。當帆布由無主變有主，或從小畫家移轉到大畫家手中，預期產值提升，配置效率也因之提升。

值得強調者，配置效率是「社會整體」判斷。如果制度費用（包括交易成本與資訊成本）為零，立法者可以全知全能，由立法者逕行將國內所有資源都分配給最能利用者⁹⁸，就能極大配置效率，乃至於更上位的效率⁹⁹。然而，現實世界中的制度費用不但為正，而且往往很高。沒有人全知全能，知道誰最能利用何物——這

95 See Lee Anne Fennell, *Efficient Trespass: The Case for “Bad Faith” Adverse Possession*, 100 NW. U. L. REV. 1037, 1064 (2006).

96 經濟分析有其強項、也有侷限。在此，經濟分析不去判斷誰的畫作藝術性較高，因為藝術性很主觀，難以納為分析的變數。因此，只能忽略藝術性，或假設藝術性較高的畫作，在市場供需法則運作下，售價也較高。

97 或許有畫家現在很窮困，無力競逐好帆布，但注定成為一代宗師。經濟分析假設運作良好的市場中，有能力者可以透過借貸獲得必要資源。若市場運作不佳，使才高者無法獲得資源，則屬經濟分析的侷限。

98 或者，立法者可以隨機分配資源。隨後，因為制度費用為零，市場可以在一瞬間透過交易使得配置效率最大。然而，此種作法會造成分配不公。

99 物權法中，效率的考量包含配置效率與生產效率。生產效率即能否用低成本方式產出有配置效率之制度或結果。參見張永健（註23），頁197。

也是中央計畫經濟會失敗的原因。透過自由市場，利用分散的知識、自願交易、私有產權，一般而言（在特定的制度費用結構下）是增進配置效率的更佳制度安排。當一人願買、一人願賣，客觀的第三人即可判斷，買家應該比賣家更珍視系爭物、更能利用系爭物¹⁰⁰。或一人願賣帆布，多人競相出價，則出價超過底價且最高者應該就是最能利用帆布者。反之，若買家苦苦哀求、不斷提高出價，所有人遲不點頭，則所有人應該是比買家更能利用該物者。靠著物權法的基本原則（財產原則），市場自願交易能讓產權流轉到更能利用者手中，因而增進配置效率¹⁰¹。

換言之，效率標準講究社會整體福利的提升，社會福利是個人福利（包括但不限於物質財富）的加總，但沒有人有讀心術或有水晶球，可以直接量化某人珍視某物之程度。所以，衡量社會福利（效率）變化的最可靠方式，是觀察個人自願行動（尤其自願交易）。不過，因為制度費用為正，自願交易不成，不總是因為交易不會導致配置效率提升，而有時會導因於交易本身的種種障礙（例如高交易成本或政府管制）。從事理論研究、制度設計的學者，可以透過理論推演預測，分析財產原則以外的制度安排，是否更能提升配置效率。因此，配置效率理論要能證成時效取得制度，必須指出前述財產原則之運作模式，在時效取得制度規範之具體事實情境中，比時效取得之法原則更不能增進配置效率之原因。

然而，現行時效取得制度，並非財產原則以外的唯一制度選

100 當然，可能買家很有錢，視錢如糞土；賣家遭逢急難，必須賤賣。沒有制度能完美，除非某法律問題的情境中常有此種情形，否則，若沒有更好的制度安排作為替代方案，吾人也只能接受現實制度的不完美。

101 在沒有明確證據時，選擇保護物權人而非無權占有人，乃因物權人通常都曾付出代價以取得系爭物（此證明了他珍視之程度）；就算沒有付出過代價（如因繼承或贈與），市場也會使物權人感知到其現行利用方式（或未利用）之機會成本。無論物權人選擇開發或保育，可以合理推測其選擇對其之價值，高於市價。

擇。補償原則（例如買家必須在法院提存系爭物之市價或再加成）即為另一種可能。當制度費用的結構是交易成本高但資訊成本低時，買家及客觀第三人或許可以確知買家比所有人更能利用該物，但買賣雙方可能因為高交易成本而無法達成交易。此時，不透過市場自願交易就移轉產權，也可能增進配置效率。但如果已經知道買家比所有人更能利用系爭物，為何還要大費周章協商或爭訟補償金額？原因就在於，民法立法者再怎麼精細，都很難設計出一套時效取得規則，使「唯有」比所有人更能利用系爭物者才可以符合構成要件。而若要求買家付出大於或等於市價之補償，至少確認了買家確實珍視系爭物到一定程度，否則其不可能願意掏腰包。再者，若所有人（被迫的賣家）可能損失產權但無法獲得任何補償，則此巨大風險會誘使他支付更高額的防範成本；而這些防範成本（每隔幾天巡邏一趟自己所有的產業，確認沒有閒雜人等侵佔）往往沒有產值，是社會淨損失。

最後，以財產原則、補償原則與現行時效取得制度相比，究竟後者較能促進配置效率的條件、理由為何？以時效取得所有權問題而言，無權占有人從不曾付錢購買系爭物，時效取得本身也不花一毛錢，單純從無權占有人使用系爭不動產十數年，所有人沒有採取法律行動，是否就可以推論前者比後者更能利用系爭物？就算多數情形下答案為肯定，為提升配置效率而動員其他社會資源（地政事務所與法院審查、裁決時效取得案件之人力物力），是否值得？這些問題，在下文接續討論。

（二）損失厭惡理論

近年來，將心理學、經濟學、法學方法結合的「行為法律經濟學」（behavioral law and economics）¹⁰²日益興盛。此種研究取徑其

¹⁰² See generally OREN BAR-GILL, SEDUCTION BY CONTRACT: LAW, ECONOMICS, AND PSYCHOLOGY IN CONSUMER MARKETS (2012); CASS R. SUNSTEIN ED., BEHAVIORAL

中一個知名發現是人的「損失厭惡」(loss aversion)¹⁰³——簡言之，損失100元的痛苦，比獲得100元的快樂還要大。另一發現是「稟賦效應」(endowment effect)¹⁰⁴——擁有某物時所要求之售價(willingness to accept)，高於未擁有該物時所願意支付之買價(willingness to pay)。有學者將此兩種實驗室中所觀察到的現象，應用到時效取得問題¹⁰⁵。此理論主張，假設長期占有人與所有人的財富差不多，無權占有人長期使用後，會覺得自己已經彷彿擁有該物，若被要求返還，會視之為損失；所有人已經許久沒控制該土地，若能要回，會視之為額外收穫。因為損失幅度大於收穫，所以應該讓占有人時效取得所有權。然而，如學者所批評，此種理論作了非常多未經檢驗的假設（所有人真的會視之為收穫嗎？無權占有人真的會認為系爭不動產已經歸其所有嗎？兩造財富都相差無幾嗎？），而這些法律情境其實並沒有在心理學實驗中被直接檢驗，學者有過度類推既有心理學研究發現之嫌。再者，心理學家沒有區分占有與所有，既有實驗中將兩者視為同一；因此，要用稟賦效應與損失厭惡來證成時效取得制度，仍嫌速斷¹⁰⁶。

LAW AND ECONOMICS (2000); RICHARD H. THALER & CASS R. SUNSTEIN, NUDGE: IMPROVING DECISIONS ABOUT HEALTH, WEALTH, AND HAPPINESS (2008); CASS R. SUNSTEIN, SIMPLER: THE FUTURE OF GOVERNMENT (2013); DORON TEICHMAN & EYAL ZAMIR EDS., THE OXFORD HANDBOOK OF BEHAVIORAL ECONOMICS AND THE LAW (2014).

¹⁰³ See, e.g., DANIEL KAHNEMAN, THINKING, FAST AND SLOW 282-86 (2011).

¹⁰⁴ See, e.g., *id.* at 289-99.

¹⁰⁵ See Robert C. Ellickson, *Bringing Culture and Human Frailty to Rational Actors: A Critique of Classical Law and Economics*, 65 CHI.-KENT. L. REV. 23, 38-39 (1989); David Cohen & Jack L. Knetsch, *Judicial Choice and Disparities between Measures of Economic Values*, 30 OSGOODE HALL L.J. 737, 751-52 (1992); Stake, *supra* note 77, at 2459-64.

¹⁰⁶ See Daphna Lewinsohn-Zamir, *What Behavioral Studies Can Teach Jurists about Possession and Vice Versa*, in LAW AND ECONOMICS OF POSSESSION 128, 136-42 (Yun-chien Chang ed., 2015).

(三) 有效率侵害理論

美國各州普通法並沒有嚴格區分善意或惡意時效取得¹⁰⁷，不過學說上則大多認為要對惡意時效取得設下較嚴格之要件¹⁰⁸。大陸法系各國則通常會因為時效取得人是善意或惡意而改變時效長短（如：臺灣民法第768條至第770條、法國民法第2272條、荷蘭民法第3編第99條、日本民法第162條），甚至不許惡意占有人時效取得（如：德國民法第937條）。

Lee Anne Fennell教授獨排眾議，倡議時效取得應限於惡意占有，且排除善意占有¹⁰⁹。詳言之，Fennell教授之論點為：時效取得之現代意義，是大部分時候不干涉「財產原則」(property rule)之運作，只在極少數的情況，利用時效取得制度作「有效率侵害」(efficient trespass)，俾使資源流轉到最能利用者手中。並無道理認為，善意無過失之時效取得人，比惡意之時效取得人，更能夠做有效率的利用。以超速為喻：明知速限而超速者，（除非是天生喜歡飆車或有反社會傾向）是因為時間成本較高，寧可繳納交通罰鍰——就像是契約法律經濟分析常講的「有效率違約」(efficient breach)¹¹⁰。但渾然不知速限而超速者，大概不是因為時間成本高，而只是心不在焉。是故，只有惡意、明知者，才可能在作有效率與否之決策；惡意行為人比善意行為人，更可能在作有效率決策。回到時效取得情境：善意時效取得人不知道自己沒有產權，不是因為自認為更能利用資源才利用此項資源；故其行為沒有揭露任何資訊。客觀的第三者無法判斷，到底是善意時效取得人還是原所有人更能利用此資源。況且，時效取得制度怎麼規定，都不會影響

107 *But cf.* R. H. Helmholz, *Adverse Possession and Subjective Intent*, 61 WASH. U. L. Q. 331 (1983)（實證研究發現，法院往往拒絕讓惡意占有人時效取得）。

108 *See, e.g.*, Ellickson, *supra* note 74; Epstein, *supra* note 77, at 673; Merrill, *supra* note 77, at 1154.

109 *See generally* Fennell, *supra* note 95.

110 關於有效率違約經濟分析之中文文獻，參見簡資修（註75），頁65-88。

善意無過失者，因為他們根本自認為是所有人。不但沒有道理給善意時效取得人更優惠的取得條件，更應該直接廢除善意取得人的時效取得權利！但若容許惡意占有人任意時效取得，當然也無助於提昇配置效率。為確保資源能向最能利用者流轉，惡意占有人必須符合三項要件，才能時效取得：第一，市場交易無法進行（因為市場交易是提升配置效率最穩妥的途徑；若市場交易能進行但未轉手，顯示了惡意占有人其實並非較能利用系爭物者）；第二，有證據顯示，惡意占有人較原所有人更能利用系爭物（配置效率無法透過自願交易而彰顯，故必須訴諸其他證據）；第三，有證據顯示原所有人知道惡意占有人對系爭物有興趣，且已開始占有；例如：惡意占有人以存證信函向原所有人出價購買系爭物¹¹¹（第二點所要求的證據並非鐵打，讓原所有人有機會表示異議，而其未異議，進一步顯示系爭物對原所有人價值不高）。

Fennell教授之論點¹¹²，非常精彩，但仍有缺陷。首先，Fennell教授之見解，是在美國普通法之情境下之解釋論。臺灣和美國的登記制度大不相同，使得資訊成本高低有很大的落差；在臺灣，惡意占有人有充足的條件可以尋求與所有人交易，所以不需要另外設立時效取得制度來特別保護惡意占有人（詳見下節）。美國案例法容許Fennell教授以解釋之方式限縮普通法的法原則，大陸法的結構則不太可能如此解釋現行民法條文。此外，Fennell教授的理論雖然容許惡意占有人有機會時效取得，但也讓惡意占有人在時效期間內隨時處於被請求遷讓的困境。無恆產、則無恆心，此種處境中的惡意占有人，相較於有權占有人，投資必然較少。再者，超速之比喻，

111 See Fennell, *supra* note 95, at 1040-41. Posner法官也強調時效取得只有在高交易成本時，才能被證立。See Posner, *supra* note 91, at 560.

112 有趣的是，也有左派物權法學者主張應該容許惡意占有人時效取得物權，並大體贊成Fennell教授的結論。See EDUARDO M. PEÑALVER & SONIA KATYAL, PROPERTY OUTLAWS: HOW SQUATTERS, PIRATES, AND PROTESTERS IMPROVE THE LAW OF OWNERSHIP 149-50 (2010).

也略嫌引喻失義。超速或維持速限駕駛，都是沒有長期效果之行為。不動產會因為投資而影響價值，但開車行為沒有類似於不動產投資之支出。無權占有人可能會被權利人趕走而使得投資無法回收（民法第956條、第957條、第958條參照），但超速者吃了罰單，其因開快車而省下的時間不用也無法吐回。

本文同意Fennell教授之基本論據：財產原則應該是物權法的原則，只有在例外情形才應該使用其他制度安排。但因為臺灣、美國物權法制與登記制度不同，依據同樣之理論，臺灣應該採用不同的制度，此為下節之內容。

二、時效取得制度改革芻議

本節將突破現行法之桎梏，思考時效取得制度之立法論，建構一套適合當代臺灣的時效取得制度。以現行法之解釋而言，本節論據可作目的解釋之素材；但本節主要著眼點在於倡議修法，改採新的時效取得制度，以回應臺灣現況。以下依土地、定著物，有、無登記，占有人為善意或惡意，分為四個小節論述。

應先強調者，以下雖時時強調交易成本、資訊成本，但並非因為經濟分析只重成本、忽略效益。常論述成本，是因為政策決定者、學者比較能夠掌握、理解、量度制度層次的交易成本與資訊成本，並藉由立法、修法、解釋法律，以降低制度費用。不同制度設計導致之制度費用，容易推斷；因此，立法者、法官比較能推知其決策對成本面的影響。反之，效益跟具體個案情境密不可分。例如：在A和B兩人之間，A是甲地的較能利用資源者，而B是乙地的較能利用資源者，但A和B誰較能利用丙地，抽象規則的決策者如立法者，甚至具體個案的決策者如法官，往往缺乏足夠資訊來判斷。所以不管是制訂、適用或解釋法律，決策者能做的往往是處理制度層次的成本問題；成本儘量壓低之後，效益如何增加，就由後續的自願交易完成。換言之，雖然下文分析只關照成本，但背後目

標仍是藉由促進自願交易，讓最能利用資源者取得產權，達到最終的配置效率。

（一）有登記不動產與惡意占有

關於有登記之不動產，本文認同現行法之規定，占有人不得時效取得所有權¹¹³。但占有人是否可以時效取得定限物權？分惡意與善意占有人兩部分說明：

本文認為應不容許惡意占有人時效取得定限物權。此與現行法之價值判斷不同，理由如下：

臺灣地政資訊非常詳盡，不但有主管機關¹¹⁴與民間組織¹¹⁵開發的各種線上查詢系統，還可以結合Google Map 和Google Earth，查詢地貌、地界、權屬等資訊。無論有沒有網路，任何臺灣人民都可以用便利的程序、不到100元之代價，查到臺灣任何一筆不動產之所有人之登記住址與部份姓名（新土地登記規則第24條之1參

113 容許惡意時效取得人取得已登記不動產之所有權，或許有一潛在用途，就是用以解決「共決」(anticommons)的問題。例如：若某地產權複雜，幾百人共有，或是有祭祀公業等，且因權利人彼此不合，長期無法使用。此時若有知情者長期占有使用，若允其時效消滅後取得所有權，則所有權歸於單一，有利於後續物之有效利用。然而，現實上知情者能成功時效取得者，幾稀矣。

114 內政部地政司，地籍圖資網路便民服務系統，<http://easymap.land.moi.gov.tw/K02Web/index.jsp>（最後瀏覽日：2014年2月14日）。由政府免費提供，以內政部地政司建置完成之全國土地基本資料庫，結合交通部運輸研究所「路網數值圖」，提供以地號、建物門牌、村里等方式查詢土地位置，再與Google Map及Google Earth結合應用，目前月平均查詢量高達20萬次以上。
Hinet地政服務，<http://www.land.nat.gov.tw/>（最後瀏覽日：2014年2月14日），則為付費服務，可依門牌或地號線上查得所有人之姓名與地址。在Hinet地政服務可以申請到全臺灣任何一筆土地或建物之電子地政謄本，而且謄本效力等同於親自至地所申請的紙本謄本，一張謄本20元新臺幣。若不需要法律效力，可以申請地政電傳，一張證明只要10元新臺幣。

115 民間組織線上查詢：如關貿地政資訊網，<http://www.land.net.tw/APLAND/>，（最後瀏覽日：2014年2月14日）、你找我找他，<http://iamyes168.pixnet.net/blog>（最後瀏覽日：2014年2月14日）、V523地產資訊網，<http://www.v523.com.tw/>（最後瀏覽日：2014年2月14日）等。

照)¹¹⁶。因此，惡意占有人若已明知不動產非其所有，則應查知真正所有人之身分，並與之協商交易。縱使認為新土地登記規則第24條之1不讓此種占有人獲得資訊較多的第三類謄本，而只能取得第二類謄本；占有人依據第二類謄本上的登記地址，也可以寄送購買意向書，請求原所有人與其聯絡。在絕大多數之情況下，聯絡上所有人的資訊成本、與其談判之交易成本，（相對於不動產之價值）都很低¹¹⁷。若惡意占有人未與所有人談判，或所有人在談判後不願意授權，則惡意占有人很可能不是較能有效率利用不動產者，否則不會無法說服所有人，或不願意花費一點搜尋成本來找出所有人，與之交易。若允惡意占有人透過時效取得而獲得權利，不符合配置效率。本文基本上同意前摘Fennell教授之見解，但Fennell教授的三個條件，是在時效取得制度存在的前提下所作之限縮解釋。本節既然著眼於立法論，而且不動產相關資訊之獲取成本，臺灣遠低於（Fennell教授論述所奠基之）美國，一律不允許惡意占有人時效取得任何物權，應該整體而言最有效率。

此外，時效取得制度之立法者如欲促進不動產利用，可以建議登記名義人留下真正常用的收信地址、手機號碼等方便聯絡之資訊（只對地政事務所公開，不對外公開），並充當資訊平台¹¹⁸。也就是，讓任何人只要願意支付一定規費，就可以透過地政事務所向登記名義人遞交購買意向書、出價。個資不洩漏，地政事務所增加收

116 無法上網使用前述Hinet地政服務者，申請人可攜帶身分證件赴地政事務所查詢。已辦理保存登記之建物與已登記之土地，可用門牌查出土地或基地之區段地號（每筆收費新臺幣10元），再用地號查出所有人（部分）姓名，同時可看到土地上是否帶有定限物權。

117 當然，少數情況中，系爭土地可能為100人共有，以致於有意利用者談判之交易成本很高。但在此種情況中，想透過時效取得制度解決此種共決悲劇，也不切實際。占有人必須有連續占有20年，沒有被100人中的任何一人抗議，才能取得某種定限物權。發生機率太低。

118 類似見解，*cf.* Stake, *supra* note 77, at 2443。要求土地所有人留下電子郵件地址、手機號碼或其他聯絡方式，也對課徵土地稅有幫助。

入、拓展業務範圍，不動產使用效率提昇！

2014年中，土地登記規則第24條之1要如何增修，有幾番重大爭議。幾方勢力拉鋸的結果，是資訊隱私派幾乎大獲全勝。筆者一向認為，個人資料保護法實施以來，各級行政機關過於激進地解釋個人資料的範疇，並往往忽略個人資料保護法的但書與例外。第二類謬本能包括的資訊多寡，又是一例。個人資訊、個人隱私固然有值得保護之處，但對立面的價值亦不容忽略。不動產登記的重要功能就是「公示」，釐清產權資訊。地政單位如何只偏重隱藏資訊，沒有顧及公示的主要功能，誠有因噎廢食之慮。如上段所建議之政策，一方面不讓個人資訊一概攤在陽光下，另一方面仍然可以促進不動產資訊流通、進而活絡不動產交易，應值主政者進一步省思。

（二）有登記不動產與善意占有

若是善意占有人占有已登記之不動產，應分為三種典型案型探討¹¹⁹：

1. 越界建築

第一種是越界建築。縱使科技十分發達，仙人打鼓有時錯，蓋房子時逾越地界並非罕見。但此種情形已經有民法第796條、民法第796條之1、民法第796條之2作為處理準據，思考時效取得制度時，毋庸再為其費詞¹²⁰。

119 認為時效取得問題應該分為三種類型探討，see Luke Meier, *A Contextual Approach to Claim of Right in Adverse Possession Cases: On Van Valkenburgh v. Lutz, Bad Faith, and Mistaken Boundaries*, 19 LEWIS & CLARK L. REV. 47, 51 (2015)（區分為無權占有、過失越界建築、法律行為嗣後被認為無效）。

120 有美國學者主張，此種案型中應要求占有人支付市價。See Stake, *supra* note 77, at 2473. 此與民法第796條之規定相合。另有美國學者擔憂，在越界建築情境，原所有人可以先刻意拖延發動訴訟之時機，再對長期無權占有人獅子大開口；是無效率的競租行為。Miceli & Sirmans, *supra* note 90, at 162-64. 臺灣民法要求「所有人即時異議」，此種問題不會發生。

2. 登記簿時效取得

第二種是先有兩造交易，經過多年後，原本之出賣人（或其他利害關係人）撤銷原本之買賣契約、物權契約（或買賣契約、物權契約被發現無效），並塗銷所有權移轉登記。若撤銷原因為買受人所不知（教科書上的例子是出賣人在締約時精神喪失，但買受人未能發現¹²¹），則買受人多年來均為善意占有人¹²²。本文在第貳部分回顧近年判決時，從來沒有遇過此種事實類型，或許這真的是只存在於教科書的例子。不過，就算真的有此種事實類型，比較恰當的處理機制，是「登記簿時效取得」¹²³，而非一般的時效取得。所謂「登記簿時效取得」，簡言之，就是某人雖無所有權但在土地登記簿上被登記為所有人，若干年後，確定取得所有權。若要在臺灣民法增訂「登記簿時效取得」制度，以保護此種善意占有人（但不保護惡意占有人¹²⁴），前提是實務上（不止是法院實務）真的有數量足夠的無效或被撤銷的債權與物權契約，無效和撤銷原因又為買受人所不知，買受人又占有不短的時間。若符合這些條件的情形罕見，應由法院在個案上適用民法的帝王條款嘗試調和當事人關係較為恰當，而非建立一整套登記簿時效取得制度。

3. 可得而知之善意占有人

第三種類型，則是占有人自始不是土地登記簿上之物權人，土

121 關於「占有人不知地上權設定無效之原因且無過失」之探討，參見謝在全（註48），頁253。

122 此種類型，美國法稱之為color of title，學者認為值得保護占有人，因為占有人已經支付過利用土地之價金，只是有些形式要件未遵守。若在一定期間內，雙方都依照契約行事，則應該讓狀態持續。See SINGER, *supra* note 62, at 162-63.

123 德國民法第900條、瑞士民法第661條有規定登記簿時效取得。詳參王澤鑑（註25），頁176。主張民法應該要引入此種制度之探討，參見例如陳重見，民法物權編所有權通則新修正評釋，月旦法學雜誌，168期，頁79-80（2009年）。

124 其他善意第三人，無論如何都受保護，此在土地登記之公信原則下，乃屬當然。

地又登記為他人所有，占有人對系爭土地之利用也不是從已有土地中延伸而出。實務上常見有占有人陳稱其家族自清季、日據、光復初期就開始使用系爭土地云云。此種長期、跨代之占有與利用，縱使沒有轉手交易，也有繼承，繼承時繼承人就有機會檢驗利用與產權之間的落差。縱使幾代人真的都因為缺乏法律知識而屬於善意，也是可得而知之善意。此外，土地要繳土地稅、房屋要繳房屋稅，在臺灣應屬常識¹²⁵。占有人若運用不動產數十年卻從未繳過稅，若非不食人間煙火，就是有意佔人便宜，並非善意占有。

時至今日，土地複丈、鑑界非常精準、快速、便宜，而且地政機關的測量結果有確定界址的法律效力。真有測量錯誤而造成無權占有，也應該設立類似「登記儲金」（土地法第68條至第70條參照）的「測量儲金」¹²⁶來賠償當事人損失，而非仰賴高度不確定的時效取得制度。設計時效取得制度時，應該由「事前觀點」¹²⁷（*ex ante viewpoint*）著眼，誘使利用不動產者多多自行或委託專業人士利用精確的不動產資訊系統，確定自己正在或即將利用之不動產之權利歸屬。就此而言，不應該容許此等類型中的占有人時效取得所有權或定限物權，蓋其並非真正「不得而知的善意」（*good-faith*）占有人，而是「可得而知的善意」（*innocent*）占有人，並不值得法

125 學者亦有論及是否繳納稅捐對於認定自主占有之影響，參見謝在全（註48），頁211。

126 參見張永健，越界建築之經濟分析，中研院法學期刊，12期，頁189（2013年）。

關於測量錯誤之損害是否屬於土地法第68條之賠償範圍，請比較謝哲勝，不動產登記法基礎理論與立法，2014兩岸四地不動產研討會，台灣財產法暨經濟法研究協會主辦（2014年6月16日）（認為不包括）；陳立夫，土地登記之損害賠償，月旦法學教室，75期，頁27（2009年）（認為包括）。

127 事前觀點在物權法之應用，參見張永健，附合與混合之經濟分析，月旦民商法雜誌，36期，頁75-76（2012年）；張永健，法定通行權之經濟分析，臺大法學論叢，41卷特刊，頁1354（2012年）；張永健，物權法之經濟分析導論（一）——事前觀點與交易成本，月旦法學雜誌，230期，頁251-254（2014年）。

律全面保障¹²⁸。

在此值得進一步論述「無過失的善意」與「可得而知的善意」之區分。時效取得情境（及許多物權法原則的情境），善意與惡意之別，就是資訊之有無。資訊之取得有成本——本文稱之為資訊成本（information cost）——但成本有高有低。若資訊成本低而資訊潛在的價值高，從社會整體之觀點，取得資訊較有效率。但如果法律永遠保護無資訊者而給予有資訊者不利待遇，當事人就有誘因要不獲取資訊（或裝成沒有獲取過資訊）。民法物權編不少條文已經認知此問題，故將面對低成本、高價值資訊而未獲取者，等同於已獲取資訊者。例如：民法第796條第1項¹²⁹、民法第881條第3項¹³⁰、民法第899條第3項¹³¹、民法第928條第3項¹³²、民法第948條第1項¹³³之「重大過失」，民法第799條之1第4項¹³⁴、民法第826條之1第2項之「可得而知」就是在描述此種狀態，而將此種行為與人與

128 區分兩種善意之理論探討，see Stewart E. Sterk, *Strict Liability and Negligence in Property Theory*, 160 U. PA. L. REV. 2129 (2012). 明確區分innocence 和 good-faith之文獻，see William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economics of Legal Disputes over the Ownership of Works of Art and Other Collectibles*, in ESSAYS IN THE ECONOMICS OF THE ARTS 177 (Victor Ginsburgh & Pierre-Michel Menger eds., 1996).

129 民法第796條第1項：「土地所有人建築房屋非因故意或重大過失逾越地界者，鄰地所有人如知其越界而不即提出異議，不得請求移去或變更其房屋。但土地所有人對於鄰地因此所受之損害，應支付償金。」

130 民法第881條第3項：「給付義務人因故意或重大過失向抵押人為給付者，對於抵押權人不生效力。」

131 民法第899條第3項：「給付義務人因故意或重大過失向出質人為給付者，對於質權人不生效力。」

132 民法第928條第3項：「其占有之始明知或因重大過失而不知該動產非為債務人所有者，亦同。」

133 民法第948條第1項：「以動產所有權，或其他物權之移轉或設定為目的，而善意受讓該動產之占有者，縱其讓與人無讓與之權利，其占有仍受法律之保護。但受讓人明知或因重大過失而不知讓與人無讓與之權利者，不在此限。」

134 民法第799條之1第4項：「區分所有人就區分所有建築物共有部分及基地之應有部分，依其專有部分面積與專有部分總面積之比例定之。但另有約定者，從其約定。」

惡意/故意者同視。由於此種情境中之重大過失主要關乎資訊成本，與侵權法中之重大過失主要關乎防範成本，有所不同，但使用同樣的名詞，恐有混淆之餘。將來修訂民法時，亦應考慮釐清之（例如都用「可得而知」）。回到時效取得問題，由於不動產通常價值甚高，而資訊科技之發展使得獲取不動產資訊之成本大大降低，以致於絕大多數之善意時效取得人其實都應該論為「可得而知之善意占有人」。

然而，或許有少數案件之當事人，真的是不得而知的善意占有人。又考量真正所有人若長期未發覺不動產遭占有，在部分案例中多少透露了他不在乎或沒需要系爭不動產的訊息¹³⁵。長期利用對比長期不在乎，有時確實是長期占有人經濟價值較高之證據¹³⁶；若允許時效取得，在某些案件中可促進配置效率¹³⁷。但是，真正所有人沒有動作，可能也出於（高資訊成本導致的）不知情，不是真的明知而不不在乎——雖然此種情形之機率確實不高。如同Fennell所論，難以確定將產權分配給善意占有人更能增進配置效率。而且，真正不得而知的善意占有人，並不多見。

兩邊相權，本文仍傾向於事前觀點，認為應該一律不允許占有人時效取得已登記土地上之定限物權¹³⁸，因為在當代臺灣不動產交

135 See MATTEI, *supra* note 3, at 116.

136 Cf. Stewart E. Sterk, *Neighbors in American Land Law*, 87 COLUM. L. REV. 55, 61-62 (1987)（都市中，通常長期占有人的經濟價格高於真正所有人）。

137 See ROBERT COOTER & THOMAS ULEN, *LAW AND ECONOMICS* 153-54 (6th ed. 2012); RICHARD A. POSNER, *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW* 154 (8th ed. 2010); Posner, *supra* note 91, at 559; Miceli & Sirmans, *supra* note 90, at 162-63.

138 此與臺灣多數說見解有所不同，參見謝哲勝（註49），頁121（主張不動產所有權取得時效客體不應以未登記不動產為限）；陳重見（註123），頁74；謝在全（註48），頁228-230註10（探討相關學說）。

與本文類似之主張，cf. Lewinsohn-Zamir, *supra* note 106, at 138（為維護土地登記簿之精確性，以色列法律對於已有經過特定登記程序之土地，不允許時效取得）。

易之資訊成本、交易成本通常並不高¹³⁹。此種清楚的法律規則，事前有助於促進交易，事後可以減少法院內的訟爭¹⁴⁰；此外，也稍稍降低所有人之監管成本¹⁴¹。在已登記土地一律不許登記簿時效取得之外任何形式之時效取得，等於是消弭了善意占有與惡意占有之分野。物權制度皆應考量財產權之穩定，而不區分善意惡意有助於達到此目的，因為（1）占有人是否是惡意，取決於證人可信度與各種證據法則，無法客觀得知¹⁴²；（2）占有人是善意或惡意是內生的（endogenous），不是外生的（exogenous）¹⁴³——亦即，占有人會因為法律規定之不同，決定是否蒐集資訊而成為惡意，或明明是惡意卻想盡辦法偽裝成善意；（3）爭執善意、惡意也會增加訴訟費用¹⁴⁴。

4. 安全閥理論與限縮之時效取得制度

誠可想像，會有認為時效取得制度不能輕廢；也可能有引用 Henry Smith 教授之「安全閥」（safety valve）理論¹⁴⁵，認為應保存時效制度以保護真正善意且對土地作極佳利用之占有人¹⁴⁶。若要留

139 從經濟分析之觀點，唯有原所有人與占有人／時效取得人間之交易成本很高時，時效取得制度才可能有效率。See Posner, *supra* note 91, at 560; Dean Lueck, *The Rule of First Possession and the Design of the Law*, 38 J.L. & ECON. 393, 415 (1995); Fennell, *supra* note 95, at 1041.

140 Cf. Sprankling, *supra* note 88, at 878.

141 See POSNER, *supra* note 137, at 154; see Stake, *supra* note 77, at 2433; Netter et al., *supra* note 77, at 220.

142 See SINGER, *supra* note 62, at 154.

143 See Jeong-Yoo Kim, *Good-faith Error and Intentional Trespassing in Adverse Possession*, 24(1) INT'L REV. L. & ECON. 1, 2-3 (2004).

144 See Ben Depoorter, *Adverse Possession*, in PROPERTY LAW AND ECONOMICS 183, 186 (Boudewijn Bouckaert ed., 2010).

145 See Henry E. Smith, *Institutions and Indirectness in Intellectual Property*, 157 U. PA. L. REV. 2083, 2128-29 (2009); Henry E. Smith, *An Economic Analysis of Law versus Equity* (Working Paper, 2010) (本文參考2010年版本，惟網路上僅有2012年版本：<http://www.law.uchicago.edu/files/files/Smith%20paper.pdf>). 中文文獻：張永健（註126），頁162。

146 近來備受矚目之臺北市華光社區拆遷糾紛，即有住戶主張時效取得所有權與地上權。見臺灣臺北地方法院100年度重訴字第586號民事判決。該案法官認

一個方便法門給這樣的長期占有人，又要儘量維持土地登記簿之公示功能，應該照如下方式建構時效取得制度：

第一，如同現行實務¹⁴⁷見解，符合時效取得之構成要件，僅使占有人取得申請時效取得定限物權之資格¹⁴⁸。不過，不同於實務見解，若原所有人起訴請求返還不動產，則占有人在事實審言詞辯論終結前，抗辯其占有情狀已符合時效取得之要件，並以反訴確認其定限物權存在¹⁴⁹，法院即應為實體上裁判¹⁵⁰。此種作法，目的在

為，國有土地已經登記，無法時效取得所有權；住戶未曾向地政機關提出時效取得地上權之申請，故亦無法取得物權。同情華光居民者，或許希望有時效取得作為爭取權益之工具。

147 參照最高法院69年第5次民事庭會議決議：「因時效而取得地上權登記請求權者，不過有此請求權而已，在未依法登記為地上權人以前，仍不得據以對抗土地所有人而認其並非無權占有。」

148 在美國，時效一過，占有人自動取得所有權。*See Klass, supra note 88, at 287 n.14.* 若時效經過當然取得，則登記制度原本的節省資訊成本功能會打折扣，因為查閱登記簿者無法確定登記簿的資訊是否正確。*Cf. Stake, supra note 77, at 2442-43.* 潛在買家與抵押銀行必須去現場判斷占有人是否為所有人，因此增加交易成本。*See POSNER, supra note 137, at 98.*

149 在第一審中，占有人可以提出此種反訴，參見民事訴訟法第259條、第260條。第一審實務上允許此種反訴之案件，參見臺灣臺北地方法院103年度重訴字第472號民事判決、臺灣臺北地方法院102年度重訴字第1040號民事判決、臺灣臺北地方法院101年度重訴字第1003號民事判決。

在第二審中，占有人可以提出此種反訴，參見民事訴訟法第446條。第二審實務上允許此種反訴之案件，參見臺灣高等法院102年度重上字第45號民事判決、臺灣高等法院97年度重上字第590號民事判決、臺灣高等法院98年度上字第281號民事判決。但請注意亦有反對見解存在，參見臺灣高等法院101年度上字第1067號民事裁定（「本件反訴並非本訴請求前提法律關係之中間確認之訴，自無於某法律關係之成立與否有爭執，而本訴裁判應以該法律關係為據，並請求確定其關係之情形；而本件亦無民事訴訟法第446條第2項第3款所定之情形。是本件原告提起反訴，核與民事訴訟法第446條第2項所定第1、2、3款之情形不符。」）。

150 詹森林教授早已主張，最高法院80年第2次民事庭會議決議（「占有人因時效而取得地上權登記請求權者，以已具備時效取得地上權之要件，向該管地政機關請求為地上權登記，如經地政機關受理，則受訴法院即應就占有人是否具備時效取得地上權之要件，為實體上裁判。本院六十九年度第五次民事庭會議決議應予補充」），可以解釋為：只要長期占有人於第二審（事實審）言詞辯論終結前，向地政機關提出時效取得地上權之申請即可。參見詹森林（註19），頁42。此見解與本文類似。匿名審查人指出，地政實務上，地政機

於保護自始至終皆為善意占有，直到被不動產所有人提訴請求返回不動產，才驚覺自己是無權占有者。此種善意占有人，不可能在時效完成後、訴訟前就向地政機關申請登記¹⁵¹。

第二，因為時效取得者在時效期間內獨佔了土地之用益，必須給付土地所有人時效期間內（亦即無權占有期間內）「相當於『市場』租金之不當得利」¹⁵²。

第三，系爭不動產既已登記，占有人推定為惡意。有意時效取得者必須舉證證明自己並非明知或可得而知。

第四，時效取得者必須自時效取得起給付地租。時效取得定限物權者必須支付地租，有司法院釋字291號解釋理由書¹⁵³作為規範依據。惟有學者認為，若當事人間本設有無償之地上權或農育權，但因有物權設定無效情形，占有人因時效取得之地上權，似有例外解為無償之空間¹⁵⁴。本文則認為，民法無論在債編的贈與、借貸，物權編的用益物權，只要碰到無償之關係，都讓「大方」的那一造，有事前或事後的反悔空間。兩造若合意設定無償之用益關係，

關對於涉及私權爭執之申請案件，會予以駁回。是故，若占有人在言詞辯論終結前申請登記，可能在法院判決前，登記申請即遭駁回。

151 謝在全教授主張，善意占有人因取得時效完成所取得之占有法益，應解為已具有期待權之性質，乃有權占有，則以對抗所有人。參見謝在全（註8），頁176。本文與謝在全教授之見解，都是為了保護善意占有人，但採取之途徑不同。謝在全教授是在解釋上認定善意占有人是有權占有，本文則是允許善意占有人在被訴請返還不動產之後，言詞辯論終結前，可以主張時效取得，從而使法院必須實體審酌時效取得。

152 依照目前實務見解，原所有人僅能請求最近五年之相當於租金之不當得利，而且其返還數額幾乎總是低於市場租金。對此實務見解之批判，參見張永健、陳恭平、劉育昇，無權占有他人土地與相當於租金之不當得利：實證研究與政策建議，政大法學評論，144期（2016年），即將出版。

153 司法院釋字第291號解釋理由書：「至因時效完成而經登記為地上權人者，土地所有人既未喪失其所有權，而仍須承受稅捐等之負擔，為平衡雙方權益，參照民法第八百七十六條之法理，當事人如就地租事項有所爭議，應由法院裁判之。」

154 參見謝在全（註8），頁176。

外人自應尊重。但物權設定既然無效，無論原因為何，占有人無償使用之法律基礎即已不復存在。占有人與不動產物權人仍可合意再設定一次無償用益關係；但既有訴訟，即表示不動產物權人無意繼續讓占有人無償使用。若法院強作解人，在不動產物權人已經無意借用的情況下，使占有人定期或不定期無償使用，一方面與民法對無償使用的權衡有所不同；另一方面不動產物權人兩頭落空（連一點補償都沒有），必定也百般阻撓，占有人之使用收益恐怕也不會順暢。故，仍以維持司法院釋字291號解釋見解，使時效取得定限物權者必須支付地租，較為妥適。

第五，唯有須投入長期投資之占有使用方式，才能時效取得定限物權。單純之通行不動產役權就不應該透過時效取得：若長期占有人之土地為袋地，自然有民法第787條等條可憑，無須仰賴時效取得制度。若長期占有人之土地並非袋地，只是多年來習慣由某處進出，則其可隨時選擇由他處通行。若長期占有人是種植竹木或建築房屋，則可取得農育權或地上權。其道理為：若無此等定限物權，則土地上之定著物，可能會被要求拆除或夷平，從事後觀點，有點可惜，而且善意占有人會無法回收其長期投資。值得注意者，農育權人之利用方式不總是需要長期投資，種稻的農夫在每一輪耕作之邊際投資，可能半年左右就可以收割，故較無必要容許長期占有之稻農時效取得農育權¹⁵⁵。就算時效取得了農育權，依照民法第850條之2第1項，因為此種時效取得之農育權未定有期限，所有人也可以隨時終止之¹⁵⁶。至於需要長期投資之農育權及地上權，依照民法第833條之1與民法第850條之2第3項，法院可以依原所有人之請求，斟酌構成要件中所列之因素，定地上權與農育權之存續期間。

155 筆者對耕種各種作物所需之固定與邊際成本，沒有概念。正文所述奠基在許多對種稻投資之假想。

156 並請注意民法第850條之2第2項之六個月前通知規定。

延伸第五點之探討：給定善意長期占有人不一定比已登記土地之真正所有人更能利用系爭不動產，要給予長期占有人時效取得某種物權的理由，應該是保障其能收穫其長期投資之果實。但時效取得所有權或定限物權真的是最好的方案？現行民法規定已經暗示了另一種可能性。若把無權占有期間看成是占有人有事實上（*de facto*）的地上權或農育權，則真正所有人出現要求返還土地時，可以想成是事實上的定限物權消滅。地上權與農育權消滅時，既存地上物如何解決，民法第839條¹⁵⁷、民法第840條¹⁵⁸、民法第850條之7¹⁵⁹已經提出一套合理的解決方案，可以讓善意無權占有人獲得一定程度保障¹⁶⁰。簡言之，此方案是：善意無權占有人可以取回土地上之出產物或工作物，但取回前應通知真正所有人，後者有權以時價購買之。如果真正所有人通知無權占有人返還土地一個月內，無

157 民法第839條：「（第1項）地上權消滅時，地上權人得取回其工作物。但應回復土地原狀。（第2項）地上權人不於地上權消滅後一個月內取回其工作物者，工作物歸屬於土地所有人。其有礙於土地之利用者，土地所有人得請求回復原狀。（第3項）地上權人取回其工作物前，應通知土地所有人。土地所有人願以時價購買者，地上權人非有正當理由，不得拒絕。」

158 民法第840條：「（第1項）地上權人之工作物為建築物者，如地上權因存續期間屆滿而消滅，地上權人得於期間屆滿前，定一個月以上之期間，請求土地所有人按該建築物之時價為補償。但契約另有約定者，從其約定。（第2項）土地所有人拒絕地上權人前項補償之請求或於期間內不為確答者，地上權之期間應酌量延長之。地上權人不願延長者，不得請求前項之補償。（第3項）第一項之時價不能協議者，地上權人或土地所有人得聲請法院裁定之。土地所有人不願依裁定之時價補償者，適用前項規定。（第4項）依第二項規定延長期間者，其期間由土地所有人與地上權人協議定之；不能協議者，得請求法院斟酌建築物與土地使用之利益，以判決定之。（第5項）前項期間屆滿後，除經土地所有人與地上權人協議者外，不適用第一項及第二項規定。」

159 民法第850條之7：「（第1項）農育權消滅時，農育權人得取回其土地上之出產物及農育工作物。（第2項）第八百三十九條規定，於前項情形準用之。（第3項）第一項之出產物未及收穫而土地所有人又不願以時價購買者，農育權人得請求延長農育權期間至出產物可收穫時為止，土地所有人不得拒絕。但延長之期限，不得逾六個月。」

160 民法第953條、第954條、第955條又提出另一套可能解決方案，但正文所述之條文是針對地上權、農育權的具體情境，與時效取得定限物權之情境更為接近，其處理方式比民法第953條至第955條更具體且恰當。關於民法第953條至第958條規定之整體評釋，筆者將以另文為之。

權占有人沒有取回，則留存之出產物或工作物歸真正所有人所有。若真正所有人覺得留存之物對其並無價值，可要求無權占有人回復原狀。若出產物尚未成熟，善意無權占有人有稍微多一點時間來收拾善後。若系爭地上物為建築物，善意占有人搬不走，可以請求所有人價購。倘若後者拒絕，雙方應該協議出容許善意占有人其後有償占有使用之期間；協議不成則由法院判決之。

（三）未登記不動產與惡意占有

惡意占有未登記不動產，應分三種情況討論：第一、土地未登記，但屬土地法第41條免予登記者¹⁶¹；第二、土地應登記而未登記；第三、未辦理保存登記之地上物。

第一種情況，土地毋須登記而未登記，本文就結論而言贊成實務見解，將免予編號登記之交通水利用地如河川、湖泊、港灣等等（土地法第41條參照）排除在時效取得客體之外¹⁶²；以免因為政府機關人謀不臧，使應由全民共享、共用之國有土地落入有心人士之手。不過，現行的實務解釋，已經將文義解釋膨脹到極限，應以明文排除此等免予登記之土地為宜¹⁶³。

應登記而未登記之土地，如前所述，數量相當稀少¹⁶⁴，假以時

¹⁶¹ 參見謝在全（註48），頁216。

¹⁶² 此外，最高法院89年度台上字第949號民事判例，亦排除森林地為時效取得客體。判例要旨謂：「森林係指林地及其群生竹、木之總稱。森林以國有為原則。森林所有權及所有權以外之森林權利，除依法登記為公有或私有者外，概屬國有。森林法第三條及該法施行細則第二條定有明文。未依法登記為公有或私有之林地，既概屬國有，則不論國家已否辦理登記，均不適用關於取得時效之規定，俾達國土保安長遠利益之目標，並符保育森林資源，發揮森林公益及經濟效用之立法意旨（森林法第一條及第五條參照），自無民法第七百六十九條、第七百七十條取得時效規定之適用。」

¹⁶³ 此見解即使在現行法架構下亦有適用。

¹⁶⁴ 本文電訪臺中中山地政事務所以及高雄美濃地政事務所，詢問是否可以由各種既有地籍資料，辨識未登記土地究竟是免予登記者還是應登記而未登記。獲得之答案是，必須要交叉比對地籍圖、空照圖等，才能勉強推測。

日甚至會在臺灣絕種。但若真有這種土地，本文也不認為應該讓明知自己沒有物權的惡意占有人逕行開始時效取得。參照英國Land Registration Act 2002之精神¹⁶⁵，立法者可以要求占有人必須通知地政事務所其時效取得之意圖，時效才能起算¹⁶⁶。占有人為前述通知時，必須檢附相關地籍資料與空照圖，使地政事務所能辨識可能之主管機關（多半應該是主管國有土地之國有財產署）。主管機關若確認系爭土地是免予登記、不能時效取得之土地，應回函通知占有人，勸其不用浪費時間。若主管機關發現系爭土地是該登記但未登記的漏網之魚，則應該立刻開始相關之土地測量與登記程序。可以想見，惡意占有人作時效取得的誘因很低（除非他預期主管機關會互踢皮球、置地政機關之通知不理），因為成功機率很低。但在臺灣此種未登記土地屬於少數，大概也是因為情況特殊才沒有被登記。若惡意占有人真的被嚇阻而另謀出路，應該是更能提升社會福祉之結果。更直接的作法，是直接禁止惡意占有人時效取得未登記土地。本文既在擘畫可用於當下及未來之時效取得制度，則未登記土地日益減少之事實自然應該納入考量。再配合本文後述見解（善意占有人也不能時效取得未登記土地之物權），可向臺灣大眾傳遞清晰的訊息：所有的土地都已經名花有主，若想要利用土地，請確認你是否有權利；若無，請透過協商交易獲得權利；時效取得只是死路一條。

實務上最重要的應該是第三種。無權占有未辦理保存登記之房屋（可能是違章建築，也可能是合於建築法規定之房屋）超過20年，該屋之所有人與事實上處分權人均未趕人，占有人能否時效取得所有權？臺灣高等法院99年度上字第693號民事判決採否定

¹⁶⁵ See Jansen, *supra* note 3, at 161.

¹⁶⁶ 制度設計上，要求占有人在占有期間交土地稅、甚至支付價金購買使用權或所有權，較能保證效率。但未登記土地不會有公告地價，恐怕估計市價也有困難，所以實踐不易。

說¹⁶⁷。本文亦傾向否定說：惡意占有人既然明知自己無權使用，就不應任意使用；若真的能對系爭建物作很有價值之利用，則想辦法找出權利人，與其談判交易。若找不到權利人，則另謀他就，而不是花20年占有，賭一個希望，而且在20年間都提心吊膽、怕被發現，因而無法在不動產上作最適投資。

（四）未登記不動產與善意占有

到底哪些類型土地屬於應登記而未登記，既有文獻並沒有提供清楚的圖像。可以想見，此種土地應該是非都市土地、或許人煙罕至、或許完全未開發。甚難想像真有人善意、真心相信自己是所有人，而且還無過失¹⁶⁸。

未辦理保存登記之定著物，相信為數不少。但有幾個人是真正之善意占有人？土地尚可想像有無意間越界或弄錯地點之情形，但定著物就算不上鎖，也很少有正常合理人（reasonable person）會弄錯自己有權使用、擁有之定著物。換言之，未登記定著物之無權占有人不但應（如前所述）推定為惡意，也很可能確實是惡意。

但若占有人能舉證證明其為善意，長期占有未辦保存登記之房屋，也有按時繳納房屋稅，其所作所為都像是所有人（此種情況應甚為罕見），則應有容許其時效取得房屋所有權之空間¹⁶⁹。占有人不應該僅因不是原始起造人就不能時效取得未登記房屋之所有權。

¹⁶⁷ 然而，該判決之簡短論理（占有人頂多取得過事實上處分權，故其所有權取得時效無從開始）頗有值得商榷處。

¹⁶⁸ 或許有人天真地相信，在臺灣還有土地先佔先贏的叢林規則。但從效率的角度，容許此等人取得所有權，不一定能提昇效率。

¹⁶⁹ Cf. Carol M. Rose, *Possession as the Origin of Property*, 52 U. CHI. L. REV. 73, 80 (1985); Carol M. Rose, *The Law Is Nine-tenths of Possession: An Adage Turned on Its Head*, in LAW AND ECONOMICS OF POSSESSION 40, 48-49 (Yun-chien Chang ed., 2015).

學者有指出，未登記之物，可以穩定產權秩序為由，承認時效取得。參見蘇永欽（註5），頁48。

若房屋屬合法建築，占有人又能備齊相關文件，可以辦理保存登記，繼而移轉所有權。若無法辦保存登記，依民法第758、759條，占有人無法辦理時效取得所有權之登記，故無法取得所有權¹⁷⁰。

此外，若占有人曾支付房屋價金給所有人或其前手，自然不用要求占有人支付房屋之市價以時效取得所有權¹⁷¹。但若占有人未曾為房屋之所有權付出任何代價，立法政策上應考慮要求占有人必須支付市價¹⁷²向原所有人購買¹⁷³。一方面，這能減少所有人之損失，也仍能保護時效取得人之長期投資；二方面，時效取得制度縱使要保障占有人可以繼續使用系爭不動產，也沒有非要讓時效取得變成免費的道理。如果時效取得地上權的人要付地租，為何時效取得所有權的人不用付價金？時效取得所剝奪者，僅是所有人（或事實上處分權人）之同意權，而不包括其索取對價之權——這就是補償原則！

170 但若依學者見解，使違章建築仍得辦理保存登記，則占有時尚未辦理保存登記之違章建築，自然得以成為時效取得之客體。參見張永健，違章建築事實上處分權之理論建構，臺北大學法學論叢，95期，頁79-84（2015年）。

171 See Stake, *supra* note 77, at 2473.

172 此之「市價」，在現行民法條文中以「相當之價額」描述之（見第788條、第796條）。但相當之價額一詞，不如市價具有清楚的規範意義。學者研究顯示，在第796條越界建築判決中，臺灣法院都慣常給予低於市價之補償，且未詳予解釋何以該種補償即可謂「相當」。參見張永健，越界建築（註17），頁338-339。可取得市價之相對人，僅限於原所有人。補償之理論依據則為占有人取得原所有人原有之所有權。此處之市價補償為學理上稱之「補償原則」（詳前），在物權編中並不罕見。反而是現行法下，占有人無須補償即可取得他人所有權，除了時效取得之外，別無他例。

173 Cf. Stake, *supra* note 77, at 2445. See Merrill, *supra* note 77, at 1145-54. But see Miceli & Sirmans, *supra* note 90, at 166; Stake, *supra* note 77, at 2466（用損失厭惡、高訴訟成本以反對補償）。

即使占有人能善意占有之原因，是（事後被發現無效或被撤銷之）贈與契約，本文認為仍應要求當初受贈之占有人支付市價，其道理如同前述無償而事後被撤銷之地上權一樣——無償是交易的例外，應該由雙方自願為之。依法律規定創設之物權，像是法定地上權或此處時效取得之權利，應該都要有償。

肆、結論

本文由時效取得之應用式微起筆，回顧2006年至2011年地方法院之時效取得判決，發現法院錯誤解釋時效取得定限物權的一個重要構成要件「以行使、取得定限物權之意思」，導致部分長期占有已登記土地者可能因而未能依現行法時效取得地上權或其他定限物權。本文接著批判時效取得之經濟分析理論：運用資訊成本、交易成本、配置效率等分析工具，並奠基在土地登記資訊的擴充與雲端化、數位化，及未登記土地快速減少之事實上，本文主張21世紀之臺灣¹⁷⁴應該大幅限縮時效取得制度之適用範疇。

本文為臺灣量身打造一套新的時效取得制度，在此提案下，即便要保護真正不得而知而善意占有已登記土地者，使其不至於全盤喪失其長期投資，仿效既有地上權、農育權消滅時之作法，都比時效取得制度更合理。退萬步言，若要用時效取得之名，也應該僅讓占有人於辦理時效取得登記後才向後取得定限物權¹⁷⁵，並要求其支付所有人從占有之始之相當於市場租金之不當得利。占有人被推定為惡意，必須自證其善意無過失。也唯有付出長期投資者，才有賦予時效取得權利之必要。

至於未登記之不動產，惡意占有人或可得而知之善意占有人，不得時效取得物權。唯有未登記之定著物，才是適合時效取得所有權之客體。占有人仍被推定為惡意，且必須能以反證證明自己為善意，且在占有期間持續占有並繳交房屋稅者，才能時效取得所有權。若占有人或其前手未曾支付價金給原所有人或其前手，則應該

¹⁷⁴ 中國之物權法也沒有承認時效取得制度，但本文係針對臺灣情況所作之分析，不當能直接套用到中國。本文之結論，也與中國不承認時效取得制度無關。

¹⁷⁵ 同見解，認為占有人辦理時效取得登記後才向後取得定限物權，參見姚瑞光，民法物權論，頁66（1989年）。

被要求支付公平市價。

要將本文見解落實於民法，則相關條文可作下列修改（劃底線者為與現行法不同之處）：

1. 刪除民法第769條，因為惡意占有人不得時效取得所有權。
2. 修正民法第770條改為：「以所有之意思，十年間和平、公然、繼續占有他人未登記之不動產，而於占有期間均為善意並無過失者，得請求登記為所有人。占有人並應以市價補償原所有人。」「占有之始」文字刪除，因為占有人一旦在時效期間內變為惡意，應該在「收拾善後」之後就放棄占有他人不動產。本文認為只應該保護長期¹⁷⁶善意之占有人。此外並新增市價補償之規定，以明「補償原則」之旨。
3. 增訂民法第770條之1：將民法第945條之3項，移為第770條之1第1到第3項；民法第944條第2項之繼續占有推定，移為第770條之1第4項。第770條之1第5項並明定：「前三條情形，占有不動產與有登記動產之占有人，推定為惡意占有。占有未登記動產之占有人，其占有推定為善意、不得而知。」此項促使物之利用人多查閱登記簿，但仍得舉反證推翻其惡意。且刪除民法第944條第1項之「以所有之意思」、「和平」、「公然」占有部分（該項「善意、無過失」占有之推定，涉及其他占有問題，本文先存而不論）。
4. 民法第772條，假定動產所有權時效取得之規定不變，修改為：「前五條之規定，於所有權以外財產權之取得，準用

¹⁷⁶ 不動產時效取得之時效期間應該多長，本文尚無能力處理。美國情境下對長時效與短時效的成本效益分析，see Matthew Baker et al., *Property Rights by Squatting: Land Ownership Risk and Adverse Possession Statutes*, 77(3) LAND ECON. 360, 360-61 (2001). 學者並以迴歸模型檢驗美國46州的時效長短，發現鄉村州的時效較長；法院效能高的州時效較短。See Baker et al., *supra*, at 365-70.

之。符合前五條之規定，但占有已登記之不動產者，準用民法第839條、第840條、第850條之7、第859條之1之規定。」準用這四條之法律效果之理由如前詳論，讓長期投資之占有人能在收穫其長期投資之果實後，了斷其與不動產所有人間之糾葛關係，較為合理。

參考文獻

1. 中文部分

- 王文字（2000），財產法的經濟分析與寇斯定理——從一則土地相鄰關係的判決談起，收於：民商法理論與經濟分析，頁131-149，臺北：元照。
- 王澤鑑（2010），民法物權，2版，臺北：自版。
- 江宛瑛（2004），論未登錄保安林地及河川地之時效取得地上權或所有權，現代地政，275期，頁24-29。
- 周武榮（1996），時效取得制度之存在理由及其對於時效取得制度要件及效力之影響，國立政治大學法律學系碩士論文。
- 林明鏘（2006），國土計畫法學研究，臺北：自版。
- 姚瑞光（1989），民法物權論，臺北：自版。
- 張永健（2012），法定通行權之經濟分析，臺大法學論叢，41卷特刊，頁1321-1372。
- （2012），附合與混合之經濟分析，月旦民商法雜誌，36期，頁74-97。
- （2013），占有規範之法理分析，臺大法學論叢，42卷特刊，頁847-932。
- （2013），共有物分割判決之實證研究，收於：張永健編，2011司法制度實證研究，頁221-264，臺北：中央研究院法律學研究所。
- （2013），芝大法律經濟學與中國物權法——方法論的展現與辨正，法律與社會科學，12卷，頁1-18。
- （2013），袋地通行權判決之實證研究，月旦法學雜誌，216期，頁211-227。
- （2013），越界建築之經濟分析，中研院法學期刊，12期，

頁153-201。

——（2014），物權法之經濟分析導論（一）——事前觀點與交易成本，月旦法學雜誌，230期，頁248-260。

——（2014），物權法之經濟分析導論（二）——效率，月旦法學雜誌，231期，頁194-205。

——（2014），越界建築訴訟之實證研究，中研院法學期刊，14期，頁319-373。

——（2015），違章建築事實上處分權之理論建構，臺北大學法學論叢，95期，頁55-97。

張永健、陳恭平、劉育昇（2016），無權占有他人土地與相當於租金之不當得利：實證研究與政策建議，政大法學評論，144期，即將出版。

許松、張梅英、陳良駿（2008），未登記土地以時效取得所有權之探討，土地問題研究季刊，7卷3期，頁20-37。

陳立夫（2007），土地法研究，臺北：新學林。

——（2009），土地登記之損害賠償，月旦法學教室，75期，頁26-27。

——（2011），土地法研究（二），臺北：新學林。

陳仲麟（2012），為環境信託開啟新視野——論私部門從事土地保育的法律工具類型，科技法學評論，9卷3期，頁45-96。

陳自強（2014），登記生效與登記對抗之間，月旦法學雜誌，227期，頁47-65。

陳重見（2009），民法物權編所有權通則新修正評釋，月旦法學雜誌，168期，頁66-80。

曾國修（2002），所有權取得時效之存在理由及其要件構成——民法物權編部分條文修正草案之檢討與建議，收於：黃宗樂教授祝壽論文集編輯委員會編，黃宗樂教授六秩祝賀——財產法學篇（一），頁179-207，臺北：學林。

黃國昌（2007），律師代理對民事訴訟結果之影響——理論分析與

實證研究間之激盪，中研院法學期刊，1期，頁45-104。

——（2008），我國勞動訴訟之實證研究——以第一審訴訟之審理與終結情形為中心（上），政大法學評論，106期，頁203-247。

——（2009），我國勞動訴訟之實證研究——以第一審訴訟之審理與終結情形為中心（下），政大法學評論，107期，頁165-228。

楊松齡（2002），時效取得制度之「未經登記不動產」之探討，收於：黃宗樂教授祝壽論文集編輯委員會編，黃宗樂教授六秩祝賀——財產法學篇（一），頁129-178，臺北：學林。

楊崇森（2014），遨遊美國法 I——美國法之源流與民刑法之運作，臺北：華藝學術。

溫俊富（2014），時效制度的根據——十七世紀到民法典制度之際法國時效觀的演化，收於：司法院謝前副院長在全七秩祝壽論文集編輯委員會編，物權與民事法新思維——司法院謝前副院長在全七秩祝壽論文集，頁227-260，臺北：元照。

葉俊榮（2010），出賣環境權，收於：環境政策與法律，頁35-71，臺北：元照。

葉秦寧（2005），不動產時效取得相關問題之法律經濟分析，國立政治大學地政研究所碩士論文。

詹森林（2004），所有物返還請求權——系列問題（四）無權占有人之三，月旦法學教室，5期，頁40-42。

鄭冠宇（2013），民法物權，3版，臺北：新學林。

謝在全（2009），地上權短期取得時效完成之效力——最高法院九六年度台上字第二三三號判決評釋，台灣法學雜誌，132期，頁81-91。

——（2010），民法物權論（上），5版，臺北：自版。

——（2010），民法物權論（下），5版，臺北：自版。

——（2014），民法物權論（上），6版，臺北：自版。

謝依婷（2012），我國不動產時效取得之研究，國立中正大學法律學研究所碩士論文。

謝哲勝（1995），財產法專題研究，臺北：三民。

——（2001），時效取得地上權，收於：蘇永欽編，民法物權實例問題分析，頁55-69，臺北：五南。

——（2012），民法物權，4版，臺北：三民。

——（2014），不動產登記法基礎理論與立法，2014兩岸四地不動產研討會，台灣財產法暨經濟法研究協會主辦，2014年6月16日。

簡資修（2001），一物二賣：有效率之不履約或債權之侵害，人文及社會科學集刊，13卷1期，頁65-88。

蘇永欽（1998），財產權的保障與大法官解釋，憲政時代，42卷3期，頁19-64。

2. 外文部分

Ayres, Ian. 2005. *Optional Law: The Structure of Legal Entitlements*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Baker, Matthew, Thomas Miceli, C. F. Sirmans, and Geoffrey K. Turnbull. 2001. Property Rights by Squatting: Land Ownership Risk and Adverse Possession Statutes. *Land Economics* 77(3):360-370.

Bar-Gill, Oren. 2012. *Seduction by Contract: Law, Economics, and Psychology in Consumer Markets*. Oxford: Oxford University Press.

Brooks, Richard R.W. 2002. The Relative Burden of Determining Property Rules and Liability Rules: Broken Elevators in the Cathedral. *Northwestern University Law Review* 97:267-317.

Calabresi, Guido, and A. Douglas Melamed. 1972. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. *Harvard Law Review* 85:1089-1128.

- Chang, Yun-chien. 2015. The Economy of Concept and Possession. Pp. 103-125 in *Law and Economics of Possession*, edited by Yun-chien Chang. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cohen, David, and Jack L. Knetsch. 1992. Judicial Choice and Disparities between Measures of Economic Values. *Osgoode Hall Law Journal* 30:737-770.
- Cooter, Robert, and Thomas Ulen. 2012. *Law and Economics*. 6th ed. Boston, MA: Pearson/Addison Wesley.
- Depoorter, Ben. 2010. Adverse Possession. Pp. 183-190 in *Property Law and Economics*, edited by Boudewijn Bouckaert. Northampton, MA: Edward Elgar.
- Ellickson, Robert C. 1986. Adverse Possession and Perpetuities Law: Two Dents in the Libertarian Model of Property Rights. *Washington University Law Quarterly* 64:723-737.
- . 1989. Bringing Culture and Human Frailty to Rational Actors: A Critique of Classical Law and Economics. *Chicago-Kent Law Review* 65:23-56.
- Epstein, Richard A. 1986. Past and Future: The Temporal Dimension in the Law of Property. *Washington University Law Quarterly* 64:667-722.
- . 1997. A Clear View of the Cathedral: The Dominance of Property Rules. *Yale Law Journal* 106:2091-2120.
- Fennell, Lee Anne. 2006. Efficient Trespass: The Case for “Bad Faith” Adverse Possession. *Northwestern University Law Review* 100:1037-1096.
- Helmholtz, R. H. 1983. Adverse Possession and Subjective Intent. *Washington University Law Quarterly* 61:331-358.
- Huang, Kuo-Chang. 2009. Does Discovery Promote Settlement? An Empirical Answer. *Journal of Empirical Legal Studies* 6:241-278.

- Huang, Kuo-Chang, Kong-Pin Chen, and Chang-Ching Lin. 2010. Does the Type of Criminal Defense Counsel Affect Case Outcomes?: A Natural Experiment in Taiwan. *International Review of Law and Economics* 30(2):113-127.
- Jansen, J.E. 2012. Thieves and Squatters: Acquisitive and Extinctive Prescription in European Property Law. *European Property Law Journal* 1:153-165.
- Kahneman, Daniel. 2011. *Thinking, Fast and Slow*. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
- Kim, Jeong-Yoo. 2004. Good-faith Error and Intentional Trespassing in Adverse Possession. *International Review of Law and Economics* 24(1):1-13.
- Klass, Alexandra B. 2006. Adverse Possession and Conservation: Expanding Traditional Notions of Use and Possession. *University of Colorado Law Review* 77:283-333.
- Krier, James E. 2006. *Property*. 17th ed. Chicago, IL: Gilbert Law Summaries.
- Landes, William M., and Richard A. Posner. 1996. The Economics of Legal Disputes over the Ownership of Works of Art and Other Collectibles. Pp. 177-219 in *Essays in the Economics of the Arts*, edited by Victor Ginsburgh and Pierre-Michel Menger. Bruxelles: Universite Libre de Bruxelles.
- Lewinsohn-Zamir, Daphna. 2015. What Behavioral Studies Can Teach Jurists about Possession and Vice Versa. Pp. 128-148 in *Law and Economics of Possession*, edited by Yun-chien Chang. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lueck, Dean. 1995. The Rule of First Possession and the Design of the Law. *The Journal of Law and Economics* 38:393-436.
- Mackaay, Ejan. 2013. *Law and Economics for Civil Law Systems*.

- Northampton, MA: Edward Elgar.
- Mattei, Ugo. 2000. *Basic Principles of Property Law: A Comparative Legal and Economic Introduction*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Meier, Luke. 2015. A Contextual Approach to Claim of Right in Adverse Possession Cases: On Van Valkenburgh v. Lutz, Bad Faith, and Mistaken Boundaries. *Lewis and Clark Law Review* 19:47-72.
- Merrill, Thomas W. 1984. Property Rules, Liability Rules, and Adverse Possession. *Northwestern University Law Review* 79:1122-1154.
- Merrill, Thomas W., and Henry E. Smith. 2010. *The Oxford Introductions to U.S. Law: Property*. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2012. *Property: Principles and Policies*. 2d ed. New York, NY: Foundation Press.
- Miceli, Thomas J., and C. F. Sirmans. 1995. An Economic Theory of Adverse Possession. *International Review of Law and Economics* 15(2):161-173.
- Netter, Jeffry M., Philip L. Hersch, and William D. Manson. 1986. An Economic Analysis of Adverse Possession Statutes. *International Review of Law and Economics* 6(2):217-228.
- Peñalver, Eduardo M., and Sonia Katyal. 2010. *Property Outlaws: How Squatters, Pirates, and Protesters Improve the Law of Ownership*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Posner, Richard A. 2000. Savigny, Holmes, and the Law and Economics of Possession. *Virginia Law Review* 86:535-567.
- . 2010. *Economic Analysis of Law*. 8th ed. New York, NY: Aspen.
- Rose, Carol M. 1985. Possession as the Origin of Property. *University of Chicago Law Review* 52:73-88.
- . 1997. The Shadow of the Cathedral. *Yale Law Journal* 106:2175-2200.

- . 2015. The Law Is Nine-tenths of Possession: An Adage Turned on Its Head. Pp. 40-64 in *Law and Economics of Possession*, edited by Yun-chien Chang. Cambridge: Cambridge University Press.
- Singer, Joseph William. 2010. *Property*. 3d ed. New York, NY: Aspen Publishers.
- Smith, Henry E. 2004. Property and Property Rules. *New York University Law Review* 79:1719-1798.
- . 2009. Institutions and Indirectness in Intellectual Property. *University of Pennsylvania Law Review* 157:2083-2133.
- . 2010. An Economic Analysis of Law versus Equity. Working Paper.
- Sprankling, John G. 1994. An Environmental Critique of Adverse Possession. *Cornell Law Review* 79:816-884.
- Stake, Jeffrey Evans. 2001. The Uneasy Case for Adverse Possession. *Georgetown Law Journal* 89:2419-2474.
- Sterk, Stewart E. 1987. Neighbors in American Land Law. *Columbia Law Review* 87:55-104.
- . 2012. Strict Liability and Negligence in Property Theory. *University of Pennsylvania Law Review* 160:2129-2156.
- Sunstein, Cass R., ed. 2000. *Behavioral Law and Economics*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Sunstein, Cass R. 2013. *Simpler: The Future of Government*. New York, NY: Simon and Schuster.
- Teichman, Doron, and Eyal Zamir, eds. 2014. *The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Thaler, Richard H., and Cass R. Sunstein. 2008. *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*. New Haven, CT: Yale University Press.

Venerable or Outdated?:

A Radical Proposal to Reform Prescriptive Acquisition Law in Taiwan

*Yun-Chien Chang**

Abstract

The prescriptive acquisition doctrine has a long history, but it is at best an obscure and infrequently used doctrine in modern Taiwan (if not elsewhere as well). An empirical survey of district court cases in Taiwan between 2006 and 2011 reveals that hardly any possessor successfully gains title or property interests through prescriptive acquisition. Part of the reason is that courts have misconstrued the doctrine. But equally important is the fact that as of 2012, less than 3.5% of land in Taiwan was unregistered—a prerequisite for prescriptive acquisition of ownership. High population density and the rise of electronic registration records also contribute to the fall of successful prescriptive acquisition of ownership and limited property interests. Does this phenomenon suggest that the legislature should loosen the requirements for prescriptive acquisitions or that the prescriptive acquisition doctrine has no role in Taiwan now? Using economic analysis of law, this article argues the latter. My policy suggestions are that possessors of real estates should be presumed to be bad-faith, and bad-faith possessors should not be eligible for any form of prescriptive acquisition. Good-faith possessors without fault should only prescriptively acquire lesser property interests on registered immovable properties or ownership of unregistered fixtures, subject to more stringent requirements.

KEYWORDS: bad-faith, good-faith, innocence, registered, unregistered, real estate, land, fixture, presumption of possession.

* Associate Research Professor & Director of Center for Empirical Legal Studies, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.